

المبحث الأول

تعريف فقه المعاملات ومميزاته

المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان:

الأول: الفقه:

أولاً: لغة:

هو الفهم مطلقاً فهو ما يَدُلُّ على إدراكِ الشَّيءِ ، والعلم به ، والفهم له ، والعلم بغرض المخاطب من خطابه(1).

ثانياً: اصطلاحاً:

عرّفه الفقهاء: بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الأعمال من حيث الحلّ، والحرمة، والفساد، والصحة(2).

الثاني: المعاملات:

أولاً: لغة:

جمع معاملة، جاء في ((اللسان)) (3) في مادة: ((عمل)) : ((وعاملت الرجل أَعاملُهُ مُعاملةً، والمعاملة في كلام أهل العراق هي المساقاة في كلام الحجازيين)) .

ثانياً: اصطلاحاً:

وهي ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد: كالبيع، والكفالة، والحوالة، ونحوها(4).

فالمعاملات من حقوق العباد ويقابلها حقوق الله، وتشمل: العبادات، والعقوبات، والكفارات؛ إذ المقصود من العبادات في الأصل تقرب العبد إلى الملك المعبود، ونيل الثواب: كالأركان الأربعة من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحوها.

وكون البيع والشراء واجباً لعارض كخوف الهلاك فإنه لا يخرج عن كونه من المعاملات، كما أن الصلاة لا تخرج مع الرياء عن كونها في الأصل عبادة؛ إلا أنه ينبغي أن ينتبه إلى أنه يذكر في المعاملات بعض العبادات كالأضحية لمناسبتها للذبائح، والقرض لمناسبته للبيع.

(1) ينظر: العين 2: 70، ومفردات القرآن ص398، ومعجم مقاييس اللغة 4: 442، ولسان العرب 5: 3450، والكلديات ص67، وغيرها.

والمناكحات وإن كانت من المعاملات لكثرتها من العبادات إذ المقصود الأصلي منها هو العبادة وهي تحصين النفس عن المحرمات وتكثير المسلمين، بل قالوا: إن

التخلي له أفضل من التخلي للنوافل؛ لذا ذكرها المحقق ابن عابدين مع المعاملات في كتاب الطهارة مع أنه ذكرها في كتاب البيوع مع العبادات (1)؛ فقال (2): ((اعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات, والأولان ليسا مما نحن بصدد. والعبادات خمسة: الصلاة, والزكاة, والصوم, والحج, والجهاد.

فقه المعاملات المالية: دراسة تحليلية وصفية لنظرية الملكية في الإسلام

Fiqh of Financial Transaction: Descriptive and Analytical Study on Ownership Concept in Islam

Mualimin Mochammad Sahid^{i*}, Amar Fettaneⁱⁱ, Mohd Faisal Mohamedⁱ

ⁱFakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

ⁱⁱDepartment of Science in Engineering, Kulliyah of Engineering, International Islamic University of Malaysia

* (Corresponding email): mualimin.sahid@usim.edu.my

ملخص البحث

إن الملكية ظاهرة من ظواهر المجتمع لا تنفك عنه أبداً وتعتبر لازمة من لوازم الحياة. وقد جاء الإسلام بمنهج شامل للحياة كلها ومن ذلك ما يتعلق بالملكية. وحب التملك غريزة فطر الإنسان عليها. والمال محور النشاط الاقتصادي في كل مجتمع وحجر الزاوية في بنيانه الاجتماعي، لذا، فقد تناول الإسلام الملكية من كافة جوانبه ونظمه تنظيمًا دقيقًا حتى لا يؤدي إلى التعدي بين الناس. تحاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على نظرية الملكية في الفقه الإسلامي من خلال بيان تعريفها، وحقيقتها، وأنواعها، وما يرد عليها من قيود. وباستخدام المنهج التحليلي من خلال الدراسة المكتبية، تم جمع أهم الموضوعات التي تتعلق بالملكية من بعض الكتب والأبحاث التي كتبها المؤلفون من الفقهاء وغيرهم، وجعلها في صورة التنظير الفقهي جمعاً للمتفرقات، وتيسيراً لتناول نقاطها المتشعبة، واختصاراً لمطولاتها التي قد تؤدي إلى صعوبة القراءة وفهمها. ومن نتائج هذه الدراسة أن نظام الملكية في الإسلام جعل معاملات الناس تسير وفق تعاليمه بشكل صحيح بحيث لا يكون هناك ظلم واعتداء فيما بينهم. أن الإسلام أباح أخذ أنواع وسائل الكسب والتملك التي لم يرد فيها نهي أو تحريم من الشرع من خلال أسباب الملكية المشروعة وحرّم أسباب الملكية غير المشروعة. ولأجل المحافظة على صلاح الناس في معاملاتهم وإزالة الضرر منهم وضع الإسلام قيوداً على أسباب التملك وأقرّ جواز نزع الملكية الخاصة جبراً في حالة الضرورة.

الكلمات المفتاحية: نظرية، الملكية، التملك، المعاملات، المصالح

مقدمة

إن الإسلام دينٌ كامل ومتكامل لا يترك أمراً من الأمور الدنيوية أو الأخروية إلا وقد جاء لها بيان واضح ومفصّل للناس لأجل سعادتهم في الدنيا والآخرة. ولذا، فإنه يمدنا بمجموعة من النظم الفاضلة التي تكون الحياة بها صحيحة طيبة صالحة. فللتعبّد نظام، وللمعاملات نظام، ولإقامة الأسرة ونموّها وانقضائها وما يترتب على ذلك نظام. وبما أن الملكية ظاهرة من ظواهر المجتمع، لا تنفك عنه أبداً، بل هي تعتبر لازمة من لوازم الحياة، جاء الإسلام بمنهج شامل للحياة كلها. من المعلوم أن حبّ التملّك في الإنسان غريزة فطر الإنسان عليها وهي في قوّتها تفوق غيرها من الغرائز إلا غريزة حب البقاء والحياة. وأن المال محور النشاط الاقتصادي في كل مجتمع وحجر الزاوية في بنيانه الاجتماعي. من أجل هذا، تناول الإسلام الملك من كافّة جوانبه ونظّمه تنظيمًا دقيقاً حتى لا يتعدّى الملاك ولا يتعدى أحدٌ عليهم.

مفهوم المال في الإسلام

إنّ الإنسان مدنيّ بالطبع، لا يستطيع أن يعيش وحده، وهو دائماً في حاجة إلى آخرين. فطبيعته أنه يعيش في جماعات، يتعاون معها وتتعاون معه، ويتبادل مع الآخرين ما هو في غنى عنه بما هو محتاج له مما في أيديهم. فهذا التبادل هو نوعٌ من المعاملات بين الفرد وغيره، وهذه المعاملات يكون موضوعها في الغالب "المال".^١

أولاً: تعريف المال

المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضّة، ثم أُطلق على كل ما يُقْتَنَى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يُطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم. ويقال: مال الرجل يمول و يَمَالُ مؤولاً و مؤولاً إذا صار ذا مال.^٢ ويُعرّف أيضاً بأنه ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار. والشئ لا يكون مالاً إلا إذا

^١ د. عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى، الملكية في الإسلام، دار المعارف القاهرة، د. ط، ص: ١٢٢ (بتصرف)

^٢ ابن منظور، جمال الدين بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر، ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م، ج ١١/ص ٦٣٦

توفر فيه عنصران، الأول أن يكون له قيمة مادية بين الناس مطلقاً سواء أكان عيناً أم منفعة.^٣ والثاني أن يكون قد أباح الشرع الانتفاع به في حالة السعة والاختيار دون حالة الضرورة. والمال أيضاً هو كل ما يمكن أن يملكه الإنسان ويتنفع به على وجه معتاد. ولا يقع اسم مالٍ إلا على ما له قيمة يباع بها، ويلزم مُتْلِفُه وإن قلت قيمته، وما لا يطرحه الناس مثل الفلّس وما أشبه ذلك. ومنافع الأعيان، مثل: سكنى الدور وركوب السيارات، تعدُّ من المال لأن مصادرها - الدور والسيارات - يجري عليها الإحراز والحيازة فعلاً، ولأن الأعيان لا تقصد لذاتها بل لمنافعها.^٤

ثانياً: أقسام المال

ينقسم المال إلى عقار ومنقول. العقار هو الثابت الذي لا يمكن نقله مثل الأراضي سواء كانت زراعية أو غير زراعية، وأملاك مبنية. أما المنقول فهو: ما أمكن تحويله ونقله من مكان إلى آخر - فهو عكس العقار -. ومثاله: ما كان على الأرض من زرعٍ وشجرٍ وبناءٍ وحيوانٍ ومتاعٍ. ونستفيد من خلال هذا التقسيم معرفة أن العقار يصحُّ أخذه بالشفعة بخلاف المنقول، وأنه لا خلاف في جواز وقف العقار، أما في صحة وقف المنقول ففيها خلاف بين العلماء، وأنه يجوز بيع العقار قبل قبضه بخلاف المنقول، وأنه يباع ما يملك المدين من منقول أولاً لو فاء دينه، ثم يباع العقار إذا لم يَكْفِ المنقول للسداد، وغير ذلك من مسائل.

وينقسم المال أيضاً إلى مثليٍّ وقيميٍّ. أما المثلي فهو ماله نظير في السوق بلا تفاوت. وأما القيمي فهو ما لا نجد له مثيلاً في الأسواق أو يوجد ولكن مع تفاوت كبير. وفائدة هذا التقسيم تظهر في مسائل، منها: أنه إذا تعدّى إنسانٌ على مال مثلي لآخر، يكون عليه مثل ما أتلّف حتى يكون التعويض على أكمل وجه. أما في المال القيمي فيضمن قيمته ما دام لا مثل له. ومنها أيضاً: أنه يصح في البيع أن يكون المثلي ثمنًا، لأنه يتعين تمامًا، كما يصح طبعاً أن يكون مبيعاً، أما القيمي فلا يصح أن يكون ثمنًا.

^٣ د. عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى، الملكية في الإسلام، ص: ١٢٢، د. محمد يوسف موسى، الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، ص: ١٦١

^٤ أحمد فراج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ١٩٩٢ م.

وتقسيم آخر، متقوم وغير متقوم. يقصد بالمتقوم ما كان مُحَرَّرًا فعلاً ويجوز الانتفاع به في حالة الاحتراز مثل العقارات والمنقولات والمطعومات على اختلاف أنواعها، إلا ما كان مُحَرَّمًا منها. وأما غير المتقوم فهو: ما لا يحرز بالفعل مثل السمك في الماء، والطير في الهواء، أو كان لا يباح الانتفاع به إلا في حالة الاضطرار، مثل الخمر والخنزير - بالنسبة للمسلم-. وتتجلى فائدة هذا التقسيم في أن المال المتقوم إذا أتلّفه شخصٌ لزمه الضمان لأنه أتلّف مالاّ اعترف الشارع بقيمته الذاتية وأباح الانتفاع به فهو مضمون بخلاف غير المتقوم فلا ضمان على متلّفه إذ لا حرمة ولا حماية له لأنه عديم القيمة، مثل لو أراق أحدٌ خمر المسلم أو أعدم خنزيرا له. وكذلك أن المال المتقوم يرد عليه البيع والهبة والوصية وسائر المعاوضات المالية، بينما غير المتقوم لا يصلح أن يكون محلا للبيع ونحوه.

وهناك تقسيم آخر للمال وهو التقسيم بالنسبة لقابلية التملك وعدمها. ومن هذه الناحية ينقسم المال إلى ثلاثة أقسام، الأول ما لا يقبل التملك ولا التملك بحال من الأحوال، وهو ما خصص للمنافع العامة كالطرق العامة والجسور والسكك الحديدية والأنهار العظيمة والحدائق العامة ونحوها. فهذه الأشياء لا تملك ولا تملك ما دامت مخصصة للمناعة العامة، فإن زالت عنها تلك الصفة عادت إلى حالتها الأصلية وهي قابليتها للتملك والتملك. فالنهر العظيم إذا حول عن مجراه إلى مجرى آخر وأصبحت الأرض التي كان يجري فيها غير مخصصة للمنافع العامة فإنه في هذه الحالة يكون قابلا للتملك والتملك.^٥ والثاني ما لا يقبل التملك إلا بمسوّغ شرعي، وهو يشمل العقارات الموقوفة والأموال التابعة لبيت المال، أو وزارة المالية الآن. فالوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تهدم أو أصبحت نفقاته أكثر من إيراده وأموال بيت المال لا يصح بيعها إلا إذا اقتضت بذلك الضرورة أو المصلحة الراجحة كاحتياج بيت المال إلى ثمنه أو الرغبة فيه بضعف ثمنه وما أشبه ذلك، لأن أموال بيت المال تحت يد ولي الأمر كأموال اليتيم تحت يد الوصي يناط التصرف في كلا النوعين بدافع الحاجة أو المصلحة الراجحة. و الثالث ما يجوز تملكه وتملكه وهو ما عدا القسمين السابقين.^٦

^٥ أحمد فراج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٤٣

^٦ أحمد فراج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٤٣

ويتلخّص من خلال العرض السابق أن المال هو العروض والمنفعة وأنه من خصائصه أن تكون حيازته ممكنة. والفرقة بين أقسام المال والمنفعة هي من قبيل الأدوات العلمية التي يستعان بها على تقدير مفهوم الملكية. وسيتم بيان "الملكية" مفصلاً في الفصل التالي.

تعريف الملكية

أولاً: تعريف الملكية عند علماء اللغة

قال الرازي: "مَلَكُهُ يَمْلِكُهُ بالكسر مَلِكًا بكسر الميم وفتح. مَلِكٌ المرأة تزوجها والمملوكُ العبد و مَلَكُهُ الشيء تَمْلِكُهُ جعله ملكاً له يُقال مَلَكَهُ المال والمَلِكُ فهو مُمْلِكٌ. والإملاكُ التزويج وقد أَمَلَكْنَا فلاناً فلانة أي زَوَّجْنَاهُ إياها وَجَّئْنَا به من إمْلَاكِه، و المَلَكُوتُ من المَلِكِ. يُقال له ملكوت العراق وهو المَلِكُ والعِزُّ فهو مَلِيكٌ ومَلِكٌ ومَلِكٌ مثل فَخِذٍ وَفَخِذٍ كأن المَلِكُ مُحْفَفٌ من مَلِكٍ والمَلِكُ مقصور من مَالِكٍ أو مَلِيكٍ والجمع المملوكُ و الأملاكُ والاسم المَلِكُ والموضع مَمْلَكَةٌ و تَمْلِكُهُ ملكه قهراً. ويقال ما في مَلِكِهِ شيء وما في مَلِكِهِ شيء وما في مَلِكَتِهِ شيء بفتحيتين أي لا يملك شيئاً وفُلانٌ حَسَنُ المَلِكَةِ أي حَسَنُ الصنيع إلى مَمَالِيكِه وفي الحديث لا يدخل الجنة سيءُ المَلِكَةِ، ومَلَأُكَ الأمر بفتح الميم وكسرهما ما يُقَومُ به يُقال القلب مَلَأَكَ الجسد، وما تَمَالَكَ أن قال كذا أي ما تَماسك. ^٧ وقال الفيروزآبادي: "إن الملك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف بانفراد. والملك بكسر الميم اسم من [ملك] والفاعل: مالك، والجمع: ملاك مثل (كافر وكفار)..^٨"، أما ابن منظور فقال في لسان العرب: "الملكية نسبة للملك والملك في اللغة حيازة الإنسان للمال مع الاستبداد والانفراد بالتصرف فيه.^٩

ثانياً: تعريف الملكية عند الفقهاء

^٧ الرازي، مختار الصحاح، ص: ٢٦٤

^٨ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، ج٤/ص٢٨١.

^٩ ابن منظور، لسان العرب، ج١٠/ص٤٩٢

من تعريفات الملكية اصطلاحاً هو هو حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكّن من يضيف إليه من انتفاعه بالملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك^{١٠}، أو قدرة يثبتها الشارع ابتداءً على التصرف^{١١}، أو هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية^{١٢}، أو هو اختصاص حاجز شرعاً يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع^{١٣}، أو " هو اختصاص الإنسان بالشيء على وجه يمنع الغير فيه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداءً إلا لمانع شرعي يمنع ذلك"^{١٤}.

ويترتب على هذا التعريف أن الشخص الذي يحوز المال بطريق مشروع يصبح مختصاً به وكان له بمقتضى هذا الاختصاص أن ينتفع به كيفما شاء وأن يتصرف فيه بكل التصرفات المشروعة، إلا إذا وجد مانع شرعي يمنعه من التصرف كالجنون والعتة. ويُمنع الغير من أن ينتفع بذلك الشيء ولا أن يتصرف فيه إلا إذا كانت له صفة شرعية تبيح له التصرف فيه كالوكالة والوصاية والولاية. وأنّ الذي يملك التصرف بالنيابة عن غيره كالولي والوصي والوكيل لا يعتبر مالكا لما يتصرف فيه، لأن قدرته على التصرف لم تثبت له ابتداءً من ذات نفسه بل تثبت له بطريق النيابة. ومن ملك التصرف ابتداءً ولكن أهليته للتصرفات ليست كاملة أو معدومة كالصغير والمجنون والسفيه يعتبر مالكا وإن حرم من التصرفات لذلك المانع الطارئ.

١٥

أقسام الملكية

أولاً: ملكية العين، تسمى ملك ذات الشيء ومادته، كملك العقار المنقول من الأموال أو الأعيان. ولا يقبل الملك في الشريعة من الأعيان إلا ما كان له منفعة لم يحرمها الشارع. فما ليست له منفعة كالخشاش من حشرات الأرض و له منفعة لكنها محرمة شرعاً كالميتة والخنزير

^{١٠} السيوطي. الأشباه والنظائر. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٣هـ، ص: ٣٤٢.

^{١١} الكمال بن الهمام، فتح القدير، ٧٤/٥

^{١٢} شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ١٧٨/٢٩.

^{١٣} مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ح ١/ص ٢٤١

^{١٤} أحمد فراج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٤٣

^{١٥} أحمد فراج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٤٣

فلا تقبل الملك ولا تعتبر مالا محترماً. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها ثمنه ".^{١٦}

ثانياً: ملكية المنفعة، وهي الملك الواقع على منافع العين دون رقبته، أو أن يملك الإنسان حق الانتفاع والاستفادة فقط مع المحافظة على عين ما يستفيد منه كقراءة الكتب وسكنى الدور بالإجارة أو الإعارة. وتستفاد في الغالب من أربعة أشياء هي: الإجارة، والعارية، والوقف، والوصية لأحد بالمنفعة.^{١٧}

ثالثاً: الملكية الخاصة، وهي ما كانت لصاحب خاص، واحداً كان أو متعدداً له الاستئثار بمنافعها والتصرف في محلها.

رابعاً: الملكية العامة، وهي ما كانت لمجموع أفراد الأمة أو ما كانت لجماعة من الجماعات التي تتكون منها أمة بوصف أنها جماعة، وذلك كالأنهار والطرق وأبنية المدن والحصون. وإقرارها للملكية العامة يتمثل في المساجد وفي الأعيان الموقوفة على جهات الخير العام.

خامساً: الملكية المتميزة، وهي ما يتعلق بشيء معين ذي صور تفصله عن سواه مثل أن يملك الإنسان رأساً من الغنم أو داراً بأكملها.

سادساً: الملكية الشائعة، وهي ما يسمى بـ"المشاع" وهو الملك المتعلق بجزء شائع في أرضه ويسمى بالحصصة الشائعة في الشيء المشترك.^{١٨}

سابعاً: الملكية التامة، وهي ما يثبت على رقبة الشيء ومنفعته معاً بحيث يثبت معه الملك فيهما جميع الحقوق المشروعة. أو يقال: أن الملك التام أن تكون فيه العين مملوكةً لصاحبها رقبة ومنفعة.

ثامناً: الملكية الناقصة، وهي ما ثبت في ذات الشيء وحدها أو في منفعته وحدها أي إن المالك يملك العين بدون منفعتها، أو يكون مالكا للمنفعة دون العين.

^{١٦} رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، حديث رقم: ٢٠٨٢.

^{١٧} مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ص ١١٢.

^{١٨} الجنيد، د. أحمد عبد الرحمن، نظرية التملك في الإسلام، مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٤٠٣/هـ ١٩٨٣ م، ص: ٢١

الملكية التامة

الملكية التامة ما يثبت على رقبة الشيء ومنفعته معا بحيث يثبت معه الملك فيهما جميع الحقوق المشروعة. أو يقال: أن الملك التام أن تكون فيه العين مملوكةً لصاحبها رقبة ومنفعة. ولا يقبل الملك في الشريعة من الأعيان إلا ما كان له منفعة لم يحرمها الشارع. فما ليست له منفعة كالخشاش من حشرات الأرض و له منفعة لكنها محرمة شرعا كالميتة والخنزير فلا تقبل الملك ولا تعتبر مالا محترماً. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ".^{١٩} ولهذه الملكية خصائص أربع، وهي: (١) حرية التصرف، ويقصد به أن المالك له أن يتصرف في العين ومنافعها بكافة التصرفات المشروعة من بيع وإجازة وغيرها من التصرفات المشروعة التي لا تتنافى مع مبادئ الشريعة وقواعدها. (٢) شمول الملكية للعين والمنفعة أي أن للمال حق الانتفاع بالشيء المملوك بأي وجه من وجوه الانتفاع ما لم يكن ذلك محرماً شرعاً كأن يجعل داره نادياً للقمار. (٣) دوام ملكية الأعيان أي أن هذا الملك يكون دائماً غير مؤقت، فليس له زمن معين ينتهي بانتهائه، حيث أنه لا يقبل التقييد بالزمان والمكان ولا ينتهي هذا الملك إلا بهلاك العين المملوكة أو بانتقاله إلى غيره بالوراثة إذا مات المالك، أو بتصرف شرعي على ناقل الملكية كالبيع والهبة. (٤) عدم مطالبة المالك ملكاً تاماً بضمان العين ولا بقيمتها إذا أتلّفها هو بغير موجب لأن الضمان لا يستحقه إلا المالك، ولا يكون الإنسان مديناً لنفسه، ولكن هذا لا يعفيه من توقيع عقوبة عليه إن كان متعدياً كالحجر عليه مثلاً، لأن المحجور عليه يمنع من التصرف في ماله ويتولاه عنه غيره.^{٢٠}

أسباب الملكية التامة

إن الله تعالى فطر الإنسان على حبّ التملك حتى يحتفظ بنوعه لعبادة الله وكسب رضاه. من أجل هذا كانت غريزة التملك نعمةً منحها الله عباده ومنة منه حتى يستقيم الكون وتعمر الأرض. وقد جاء الإسلام بأحسن الطرق والوسائل التي تعمّر الكون تحيل

^{١٩} رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، حديث رقم: ٢٠٨٢.

^{٢٠} أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٤٥

الحياة حركة دائبة جادة، وسائل ليس فيها غش أو خداع وليس فيها تلاعب أو إخافة سبيل، وهي وسائل تضمن للفر الحياة الكريمة وتدفعه إلى ميدان العمل بكل شوق ولهفة. وفي الصفحات الآتية سوف أتعرض لذكر طرق ووسائل التملك الشرعية والوسائل التي نهى عنها الشرع. ومن الأسباب للملكية التامة ما يلي:

الأسباب المشروعة للملكية التامة

إن الأصل في الأشياء قبل حيازتها الإباحة ثم بعد حيازتها تقوم بين الشئ وبين من حازه علاقة اختصاص تمنع غير حائزه من أخذه والانتفاع به وتتيح لحائزه الانتفاع به والتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات. وبناءً على هذا، فالملك طارئٌ على الأشياء، وهذا الملك قد يثبت ابتداءً كما في الاستيلاء على المباح، وقد ينتقل من مالك إلى مالك آخر، وقد يثبت خلافه، أي أن يخلف شخص فيما كان يملكه. وأسباب هذه الملكية أربعة، وهي: حيازة المباح، والعقود الناقلة للملكية، والإرث، والشفعة.

حيازة المباح أو وضع اليد عليها.

وهو سبب منسئ للملكية، فيوجد لها بعد أن لم تكن، بخلاف بقية الأسباب، فإن الملكية تكون ثابتة قبل تحقق السبب وبسببه تنتقل من شخص إلى آخر. فالبيع مثلاً ينقل من ملك البائع إلى ملك المشتري، وكذلك الميراث، والشفعة. أما التملك بوضع اليد على المباح فإنه يثبت ابتداءً بوضع اليد، وقد كان المال قبل الاستيلاء عليه غير مملوك لأحد، وبه صار ملكاً للمستولي عليه. ومثال ذلك الصائد، فإذا صاد سمكة ملكها بالصيد ولم تكن قبل الصيد ملكاً لأحد. فالحيازة أساس لكل ملكية وجدت ابتداءً في هذا الوجود.

وهو أيضاً سبب مختصٌّ بالأموال المباحة وهي جميع ما خلقه الله تعالى في الأرض لينتفع به الناس أجمعين مما لم يحزه أحد كالأشجار التي تنبت في الجبال أو الصحراء والغابات وليست مملوكة لأحد، وكالسمك في البحر والمعادن في باطن الأرض.^{٢١}

بالإضافة إلى أنه سبب فعلي لا يتحقق إلا بالفعل، ولهذا صح من كل من يستطيعه ويقدر عليه ولو لم يكن أهلاً للإلزام والالتزام كالصبي، والسفيه، والمجنون. فمن استولى منهم

^{٢١} علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص: ٢٧

على مال مباح أصبح باستيلائه عليه مالكا له وإن لم يستطع أن يملك مثله بشرائه من مالكة بغير واسطة. والاستيلاء على المباح يشمل أربعة أضرب، هي: (١) إحياء الموات، (٢) الاستيلاء على المعادن والكنوز، (٣) حيازة الأشياء المباحة، (٤) الصيد.

إحياء الموات

يراد به الأرض الموات وهي الأرض التي لا يملكها أحد، ولا يتعلق بها حق لأحد، ولا ينتفع بها بأي وجده من وجوه الانتفاع لسبب من الأسباب المانعة من الانتفاع كانقطاع الماء عن الأرض أو لغلبته عليها أو لسوء تربتها أو غير ذلك من الأسباب. وسميت الأرض التي لا ينتفع بها مواتا لشبهها بالحيوان الذي بطلت منافعه بموته، فإذا انتفع بها حيت.^{٢٢} وعلى ذلك، فالأرض المملوكة لا تعد مواتا، وكذلك إذا كان ينتفع بها بوجه من الوجوه ولو بغير الزراعة، كالأرض التي يتخذها الناس مكانا للإلقاء القمامة أو وضع الأتربة. من شروط إحياء الموات: أن لا تكون الأرض مملوكة لأحد، فإن كانت مملوكة فلا يصح تملكها بالإحياء، وأن تكون الأرض خارجة عن العمران، فلو كانت داخل العمران فلا تعتبر مواتا ولا يجوز لأحد أن يملكها حتى ولو كانت غير منتفع بها، وألا يتعلق بالأرض حق لأهل البلد، فإن تعلق بها حق لأهل البلد لم تكن مواتا ولم يجز لأحد أن يملكها بالإحياء، وإذن الإمام كما ذهب إليه أبو حنيفة^{٢٣} خلافاً للشافعي وابن حنبل.^{٢٤}

كيفية تحقق إحياء الأرض

إحياء الأرض وجعلها صالحة للزراعة أو للانتفاع يتحقق بإزالة المانع من الانتفاع بها. فإن كان مواتها بسبب غمر المياه لها، فإحياءها يكون بتخفيف الماء وإقامة السدود حولها،

^{٢٢} أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٤٨. حمد عبد الرحمن الجنيد، نظرية التملك في الإسلام، ص: ٣٤.

^{٢٣} محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام، دار إحياء التراث العربي، ط ٤، ١٣٧٩هـ، ج ٣/ص ٧٥. و انظر: أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٥٠.

^{٢٤} أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٥٠. قُلْتُ: إن رأي أبي حنيفة أولى بالأخذ به من رأي الإمام الشافعي في هذه المسألة، ذلك لقطع المنازعات بين الناس الذين جُبلوا على حب التملك. ومع فساد الزمان، شاع فيما بين الناس التحاسد، وعدم الرضى بالقليل، والعداوة وغيرها من الصفات المذمومة. وقطعا وتفاديا لوقوع هذه الأمور يحتاج إلى تدخل الإمام (ولي الأمر) وإذن في قضية إحياء الموات. ثم إنه من الجدير بالذكر أن التعامل بإحياء الموات كاد أن يتلاشى في هذا الزمان ولم يعد للناس القدرة على القيام به. وذلك، لأن القوانين والنظم الحديثة في جميع الدول تعترف بأن الأراضي بما فيها من مياه ومعادن وكنوز وغيرها ملك للدولة، ليس لأحد التصرف بها إلا بإذن الدولة (الحكومة).

وإن كان السبب في مواتها عدم وصول المياه إليها يكون إحيائها بتوصيل الماء إليها إما بحفر بئر أو شق ترعة. وإن كان السبب فساد تربتها فإحيائها يكون بحريتها وسقيها وإصلاح هذه التربة الفاسدة. أما إذا كانت الأرض تقصد للبناء فإحيائها يكون بالبناء عليها أو إنشاء سور حولها وما شاكل ذلك.^{٢٥}

الاستيلاء على المعادن والكنوز

المعادن جمع معدن، والمعدن هو ما يوجد في باطن الأرض بخلق الله تعالى سواء كان سائلا كالنفط أو صلبا كالذهب والحديد. والكنوز جمع كنز، والمراد بالكنز هو ما دفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض من الأموال سواء أكان في الجاهلية أم في الإسلام. وقد اختلف العلماء في حكم الاستيلاء على المعادن على قولين:

الأول: رأى المالكية أن المعادن بجميع أنواعها مثل البترول، والذهب، والنحاس، والماس وغيرها لا تعتبر من الأموال المباحة، فلا يملكها من وجدها واستولى عليها، ولا يملك تبعاً لملكية الأرض، بل تكون ملكاً للدولة يتصرف ولي الأمر فيه على حسب ما تقتضي به المصلحة. فله أن يستغلها بماله لمصلحة الدولة، وله أن يقطعها للأفراد أو للشركات نظير مال أو مجانا إذا رأى المصلحة في ذلك. واستدل المالكية بأدلة، منها: أن الأرض إنما تقصد للانتفاع بظاهرها للزراعة أو البناء، ولا تقصد لما فيها من المعادن. لذا، يبقى ما في باطنها من المعادن على ملك المسلمين يتولاه عنهم ولي أمرهم ويستغله لمصلحتهم. ومن الأدلة أيضاً: أن المعادن قد يجدها شرار الناس، فإن تركت لهم أفسدوا، ولأنها على العموم مدعاة إلى التحاسد والتقاتل وسفك الدماء، فجعلت لولي الأمر درءاً لكل هذه المفاسد وما ماثلها.^{٢٦}

والثاني: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المعدن بجميع أنواعه إن وجد في أرض مملوكة لشخص كان ملكاً لذلك الشخص، وإن وجد في أرض مملوكة للدولة كان ملكاً للدولة، لأن المعادن تابع للأرض لكونه جزءاً منها، والأرض إذا ملكت ملكت بجميع أجزائها. أما إذا وجد في أرض مباحة غير مملوكة كان ملكاً للواجد، لأنه مباح تبعاً للأرض،

^{٢٥} أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٥٠-٥٢.

^{٢٦} الدسوقي، حاشية الدسوقي، ٤٨٥/١.

فيملك بالاستيلاء عليه. وإن وجد في أرض موقوفة كان وقفاً تبا للأرض، فيصرف في مصالح الوقف ولا يعطى المستحقون منه شيئاً لأنه ليس من غلات الأرض.^{٢٧}

وأما حكم الكنز، فهناك نوعان من الكنوز الكنز الإسلامي، وهو ما وجدت به علامة تدل على أنه دفن بعد ظهور الإسلام. والكنز الجاهلي، وهو ما وجدت به علامة تدل على أنه دفن قبل الإسلام.^{٢٨} والكنز الإسلامي لا يعد من الأموال العامة المباحة، فلا يتجاوز لمن عثر عليه أن يملكه، بل يأخذ حكم اللقطة فيعرفه، فإن وجد صاحبه أو وارثه سلم إليهم، وإن لم يوجد تصدق به على الفقراء. أما الكنز الجاهلي فإنه إذا عُثر عليه يكون حُصَّه للخرانة العامة، والباقي للواجد إذا كانت الأرض غير مملوكة — على خلاف في ذلك^{٢٩}

حيازة الأشياء المباحة

ومن أسباب الملكية حيازة الأشياء المباحة التي تشمل: الماء والكأ (الحشائش) والغابات. كل هذه الأشياء مباحة وحيازتها سبب لمليتها.

وفي الماء اتفق الفقهاء على أن مياه البحار والأنهار والعيون في الجبال منفعة عامة يحق للناس جميعاً الانتفاع بها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاثة، الماء، والكأ، والنار". وإذا أخذ شخص جزءاً من هذه المياه وأحزها بوضعها في إناء ونحوه، فتكون ملكاً له، ولا حق لأحد غيره فيه لأنه وإن كان مباح الأصل، فقد صار بالاستيلاء عليه مملوكاً خاصاً لمحرزه. وأما الكأ فهو الحشائش التي تنبت بغير زرع أحد. فحكمه أنه إذا نبتت في أرض غير مملوكة لأحد كالجبال والصحاري أو نبتت في أرض مملوكة ملكاً خاصاً ولم يكن صاحب الأرض أعدها وهياًها لإنباته أو لم يقيم بسقيه والعناية به، فإن ذلك مباح للناس جميعاً من غير تخصيص أحد، للحديث السابق. ولا تنزل هذه الإباحة إلا بالاستيلاء عليه وإحرازه. وأما الصيد، فيعتبر وسيلة أولى في حياة البشرية وإن كانت لا تنال حتى الآن مورداً اقتصادياً هاماً للإنسان كالسمك واللالئ والمرجان وما شابه ذلك. والأصل في حل

^{٢٧} النووي، المجموع شرح المذهب، ٦/٧٧. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ٣/٦٣. ابن حزم، المحلى، ٣/٢٣٨.

^{٢٨} أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٥٢.

^{٢٩} أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٥٣.

الصيد القرآن والسنة. فالقرآن قوله تعالى: "يسألونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين..." الآية ٣٠. وقال تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا" ٣١. ومن السنة: أن أبا الثعلبة قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي أو بكلي الذي ليس بمعلم أو بكلب معلم فما يصلح لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدرت ذكاته فكل." (رواه البخاري) ٣٢

والصيد هو اقتناص الحيوان المباح الممتنع عن الإنسان وأخذه بحيلة ودقة نظر، إما لطيرانه في الهواء أو اعتصامه بالتلال والجبال، أو بفراره في الغابات أو بسباحته في الماء. وحيوان الصيد من قبيل المباح الذي لا مالك له، فكل إنسان الحق في أن يمتلكه بالاستيلاء عليه وصيده إلا صيد الحرم، فإنه لا يملك بالاستيلاء عليه. ٣٣

العقود الناقلة للملكية

يعتبر سبباً أعظم من أسباب الملكية شأناً وأكثرها وقوعاً لأنها الطريق الطبيعي لتلبية حاجات الناس وإشباع رغباتهم. وهذه العقود كثيرة، منها: البيع، والهبة، والصدقة، والوصية، وغير ذلك. ولا يكون هذا السبب إلا في الأموال المتقومة، وهي الأموال التي يجوز الانتفاع بها، فتنتقل به ملكيتها من شخص إلى آخر بناءً على التراضي بينهما. فالبيع مثلاً ينقل الملك من البائع إلى المشتري الجديد.

الملكية سببها الإرث

وهو أن يحل الوارث محل مورثه فيما كان له من أموال أو حقوق مالية عند وفاته. ويعتبر هذا السبب للتملك جبريًّا. وذلك أن الله تعالى قد قسم الله الميراث في القرآن الكريم

٣٠ سورة المائدة، آية: ٤

٣١ سورة المائدة، آية: ٢

٣٢ العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩هـ، ج ١٢/ص ١٤

٣٣ أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٥٥

بآيات سورة النساء، منها قوله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾^{٣٤}، ويقول تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^{٣٥}

إن الإرث^{٣٦} ناقل للملكية، وليس منشئاً لها، كما أنه يتميز عن غيره من الأسباب بأنه ناقل للملكية جبراً عن الوارث والموروث حتى لو أن الوارث رفض نصيبه لا يقبل رفضه. فإذا توفي شخص وكان له ابن أو أب أو أم، فإن كلا من هؤلاء يحل محله في جميع ما يتولاه من مال عقاراً كان هذا المال أو منقولاً. ويثبت للوارث فيما تركه له مورثه، ملك تام باعتباره خليفة عنه، ولذا لا يحتاج في ثبوت هذا الملك إلى قبول. ولا يكون الميراث إلا في مال مملوك أو حق ملحق به ولا يكون إلا فيما بقي منه بعد تجهيز الميت ودفنه وإخراج الديون على الميت وتنفيذ وصاياه في حدود الثلث ثم يقسم الباقي على الورثة طبقاً لأحكام الموارث.^{٣٧}

الملكية سببها الشفعة

الشفعة هي تملك العقار المبيع كله أو بعضه جبراً عن مشتريه بما قام عليه من الثمن والمؤن رضي أم أبي. ودليل ثبوت الشفعة ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت

^{٣٤} سورة النساء، آية: ٧

^{٣٥} سورة النساء، آية: ١١-١٣

^{٣٦} من حكم تشريع الإرث: أنه من العوامل التي تنشط الإنسان في العمل وتدفعه إلى الكسب كما تدفعه إلى الإبداع فيه وعلى حسن الإنتاج في الحياة، لأن الإنسان يدرك أن ما يحصل عليه من ثروة في الحياة، فإنه يستخدمها في طاعات الله تعالى وتوفير راحته وأن جهده الذي بذل في سبيل ذلك سوف لا يذهب سدى، وإنما سيحصل عليه أولاده ومن له علاقة به من محارمه. وفي ذلك الخير له ولهم حيث لم يترك ورثته ضياعاً عالة يتكففون الناس. (د. حمد العبد الرحمن الجنيدل، نظرية التملك في الإسلام، ص: ٤٨-٤٩).

^{٣٧} أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٥٩

الطرق فلا شفعة".^{٣٨} ولكن إذا تمت الشفعة بالتراضي فإنه يملك العقار في تلك الحالة بالتراضي، أما إذا لم يحصل تراضي فإنه يملكه بحكم القاضي. وتسقط الشفعة بسبب من الأسباب منها التنازل عن الشفعة بعد ثبوت البيع، ورضا الشفيع بمشاركة المشتري له في الحوار، وتأخير طلب الشفعة بلا عذر، وقيام الشفيع بجزء من العقار، وموت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع فيه.^{٣٩}

أسباب الملكية غير المشروعة

هناك أسباب لا يجوز للشخص أن يتخذها وسيلةً لكسب المال (للملك). والسر في النهي عنها ما فيما من الظلم والخداع والإجحاف بالمسلمين، وهذا ينافي قواعد الشارع "المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً. ففي مقارنة هذه الوسائل تباعد الناس وتنفير بعضهم من بعض ونشر للفوضى وقلة الأمن بين الناس وحبس الحريات وإهانة الكرامات. كل هذه الوسائل التي تحمل هذه السيئات لحظها الشارع وحرّمها.

ومن أبرز هذه الوسائل للكسب المحرم في الشرع ما يلي: بعض العقود المنهي عنها، الاحتكار، التسعير، الربا، الرشوة، قطع الطريق وغيرها من الوسائل المحرّمة. ففي تحريم هذه الوسائل كبخّ لجمّاح العابثين وحفظ لأموال المسلمين.

والشرع عند نهي عن بعض العقود، فإنه يحرص على أن يزيل ويبعد الظلم بأنواعه في أهم ما تقوم به حياة الناس مثل: المبادلة، والانتفاع، والمعاوضات المالية بينهم. وهذا ما يعبر عنه في الفقه الإسلامي بالمعاملات، ومن أكبر المعاملات: البيع والشراء والإجارة. ولأجل هذا، نظّم الشرع ما يكفل للناس بقاءهم، فنظّم البيع المبرور الصادق، الخالي من الغش، والدغل، واعتبر ما عدا ذلك من البيوع القائمة والعقود المبنية على الغرر والجهالة ما شابه ذلك منه عنها.

ومن العقود ما هو منهى عنه لذاته؛ مثل الخمر، والخنزير، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. فهذا الذي وقع النهي عنه لعله في ذات العقد لا تتصل بالثمن ولا بالمتعاقدين.

^{٣٨} الحديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، حديث رقم: ٢٠٦١.

^{٣٩} الخفيف، الشيخ علي، المعاملات الشرعية، ص: ٣٩.

ففي بيع الخمر والخنزير والميتة، علة تحريم هذه البيوع هو نجاسة عينها، ولأنها محرمة في ذاتها. وفي مهر البغي - الذي هو ما يعطى ثمنا لبيع عرضها - محرم من أي طرفز فهو حرام من المعطي وحرام على الآخذة، وذلك لما فيه من مضرة المجتمع إذ فيه فشو الزنى وانحطاط المجتمعات وانتشار الفوضى واختلاط الأنساب. وفي حلوان الكاهن - الذي هو ما يُدفع للكاهن (المدعي معرفة الغيب وما لا يطلع عليه ويموّه على الناس أمورهم) على ما قدمه من خدمة لمن جاء له إما لمعالجة أو نحوها. ويحرم هذا لما ينطوي عليه الكاهن من غش وكذب واحتيال وقد يصل أحياناً إلى أن يشرك بالله.

ومن العقود أيضاً ما هو منهي عنه لاشتغال العقد على الغرر والجهالة. ويرجع سبب تحريم هذه العقود لما فيها من الغرر والجهالة المؤديين إلى الشقاق والنزاع بين المتعاقدين، وهو كثير، من أمثلته: بيع حبل الحبله وهو أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، وقيل أنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال. ويرجع سبب التحريم إلى وجود الغرر، إذ إن الناقة قد لا تنتج، فيحصل بذلك الغبن والجهالة في المبيع. و منها أيضاً: بيع المنابذة والملازمة والحصاة، وبيع المضامين والملاقيح.

ومن العقود ما هو منهي عنه لاقترانه بوصف يضر أحد المتعاقدين، مثل: بيع التصرية، وبيع التدليس، وبيع الغبن، وبيع النجش. فهذه البيوع لها ضرر إما بالثمن كالنجش، لأنه زيادة البيع كبيع التصرية، أو بالعائد كالغبن ونحوه.

ومن العقود ما هو منهي عنه لوصف خارج عن العقد والمتعاقدين، ومن أمثلته: البيع بعد نداء الجمعة، فنهي عنه لما فيه من الصد عن ذكر الله، وإلا فالعقد صحيح والبيع ليس فيه أي غش أو حيلة. ومنها: بيع السلاح للحربي، وبيع العصير لمن يتخذه خمرًا.^{٤٠} فهذه بعض المعاملات - وهي وسائل للكسب والتملك - التي نهى عنها الشرع وحرّمها لأجل مصلحة الناس. فكل وسيلة أو معاملة أدّت إلى الضرر، والظلم، والجهالة مثل الربا، والرشوة، والسرقه، وقطع الطريق، القمار والميسر جاء الشرع بتحريمها.^{٤١}

^{٤٠} أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٥٣-٥٩ (بتصرف)

^{٤١} أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٦٧ وما بعدها.

الملكية الناقصة

هي ما ثبت في ذات الشيء وحدها أو في منفعتها وحدها أي إن المالك يملك العين. للملكية الناقصة ثلاثة أنواع، النوع الأول: أن يكون المالك مالكا للعين دون المنفعة، وهذا النوع أقل أنواع الملك الناقص وجودا، لأنه جاء على خلاف الأصل، لأن المقصود من الملك هو الانتفاع بالعين بها. كان ذلك خلاف الأصل وقد أجاز تشجيعا لأعمال البر حيث لا يثبت إلا في الصورتين، الأولى: أن يوصي المالك بمنفعة عين مملوكة له لشخص طوال حياته أو لمدة معلومة ثم يموت فينتقل إلى الورثة دون المنفعة، وللموصى له المنفعة طوال حياته أو المدة المحددة، وعلى الورثة تسليم العين إلى الموصى له بالانتفاع، فإن امتنعوا أجبرهم الحاكم^{٤٢}، والثانية: أن يوصي شخص بأرضه لشخص ويوصي بمنفعتها لشخص آخر، فإذا مات الموصى له بالأرض أصبح مالكا للعين وحدها، ويصبح الموصى له بالمنفعة مالكا بالمنفعة وحدها، وكلاهما ملك ناقص ويجب تسليم العين لمالك المنفعة. ولهذا النوع من الملك الناقص أربع خصائص منها أن مالك العين ليس له الانتفاع لا بنفسه ولا بغيره، فلا يمكن غيره منه بأجر أو بدون أجر، وأن مالك العين لا يجوز له التصرف في العين تصرفا يضر مالك المنفعة، وأن مالك العين إذا أتلّفها ضمن المنفعة لمالكها، وأن مالك العين إذا مات انتقلت العين إلى ورثته، وأن نفقات العين اللازمة لاستيفاء المنفعة والضرائب المقررة عليها يكون على مالك المنفعة^{٤٣}.

أما النوع الثاني فهو مالك المنفعة وحدها^{٤٤} من خصائص هذه الملكية أنها تقبل التقيد ابتداءً بالزمان والمكان والصفة حسب الشروط أو المعارف عليه أيا كان السبب، مثل الإجارة حيث تعتبر المدة عنصرا أساسيا فيها. ومنها: أن مالك المنفعة يضمن العين إذا تعدى عليها لأنه تعدى على ملك غيره، وأن نفقات العين وصيانتها على مالك المنفعة وذلك إذا ملكها بدون عوض كالإعارة والوصية. وتنتهي الملكية في هذا النوع بواحد من هذه

^{٤٢} أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٦٥

^{٤٣} أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٦٥

^{٤٤} أو حق الانتفاع الشخصي.

الأمر وهي : انتهاء المدة المحددة، أو هلاك العين المنتفع بها، أو وفاة المؤجر والمعير لزوال صفة التملك، أو وفاة من له حق الانتفاع عند الحنفية.

أسباب الملكية الناقصة

أسبابها أربعة وهي: الوقف، والوصية، والإجارة، والإعارة. أما الوصية فإن الموقوف عليه له أن ينتفع بالموقوف إما بالاستغلال أو بالاستعمال إن نص عند إنشائها على أن له أن ينتفع كيف شاء. وإن نص على واحد منهما ومنع من الآخر كأن ينص على الاستعمال ويمنع من الاستغلال أو بالعكس، فليس هي التي تنظم طريق الانتفاع وبمقتضاها يتمكن المنتفع من الموقوف. ولذا، ورد عند كثير من الفقهاء أن شرط الواقف كنص الشارع لأن الوقف يأتي من قبله فيلزم العمل بشرطه.^{٤٥} وأما الوصية فهي من خلال الطريقتين وهما أولاً: أن يوصي شخص بمنفعة عين من أعيان تركته مدة معلومة أو مطلقاً ويوصي برقبته لشخص آخر فيملك الموصى له منفعة العين بالوصية في حين يملك الآخر رقبته دون منفعتها حتى انتهاء المدة فتصبح العين ومنفعتها ملكاً له. وثانياً: أن يوصي شخص بمنفعة عين من أعيان تركته مدة معلومة لواحد على أن يبقى ملك الرقبة للورثة، ففي هذه الحالة يستحق الموصى له بالمنفعة الانتفاع طيلة المدة وبعدها تعود المنفعة للورثة ويصبح ملكهم لها ملكاً تاماً.^{٤٦}

وأما الإجارة فإن المستأجر يملك منفعة العين المؤجرة خلال مدة الإجارة، وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبغيره. فإن استأجر داراً ليسكنها فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر. أما إسكان من هو أكثر منه ضرراً فلا يجوز. ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها لأن المنفعة أصبحت مملوكة له، فيجوز أن يستوفيها بنفسه أو نائبه.^{٤٧}

وأما الإعارة فهي بأن المستعير يملك المنفعة، لأن المنافع قابلة للملك كالأعيان، والتمليك نوعان بعوض وبغير عوض، ثم الأعيان تقبل النوعين، فكذا المنافع، والجامع دفع الحاجة إلا أن المستعير وإن كان مالكا للمنفعة إلا أنه لا يملك أن يؤجر لأن

^{٤٥} أبو زهرة، محمد، الملكية ونظرية العقد، دار الفكر العربي، القاهرة، ص: ٨٠-٨١

^{٤٦} عبد الله عبد العزيز المصلح، الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية، آله كاتبة، ١٣٩٦هـ، ص: ٣٨

^{٤٧} عدنان خالد التركماني، ضوابط الملكية، ط١، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، ص: ١٩

الإجارة لازمة بخلاف العارية.^{٤٨} أما الشافعية والحنابلة فيرون أن الإجارة إباحة للمنافع وليست تملكها لها، ولهذا، فإن المستعير لا يملك أخذ العوض عليها، فلا يملك نقلها إلى غيره.^{٤٩}

قيود الملكية

إن الإسلام حين أقر الملكية واعترف بحق المالك في الانتفاع بملكه وحق التصرف فيه طوال حياته وبعد مماته، لم يتركه حراً بلا حدود وقيود، وإنما قيده ببعض القيود، منها: قيود أسباب الملكية وقيود الاستعمال والتصرف ونزع الملكية الخاصة^{٥٠}

من المعلوم أن الإسلام حدّد أسباب اكتساب الملكية والطريقة التي يحصل بها الإنسان عليها، وأنه بدون هذه الأسباب لا ينتقل الملك إليه، وعلى هذا، فإن المال لا ينقل بالوسائل المحرمة كالربا، والغصب، والسرقه، والغش، والخداع وما إلى ذلك، لأن الله تعالى حذر من اكتساب المال الحرام وهدّد الرسول صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بقوله: "كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به". ولما كان الهدف والمقصد من تملك الأموال هو ما تحقّقه من فوائد لأصحابها والانتفاع بها من أجل هذا، قيّد الإسلام الاستعمال وجعله محصوراً في الفوائد التي تعود على الفرد والمجتمع ونظمه بأمور، منها:

بإحسان الانتفاع والتصرف في الأموال. وذلك لأن الشريعة الإسلامية دعت المالك إلى إحسان الانتفاع والتصرف في أمواله، فلا يضيعها ولا يتلفها ولا ينفقها فيما لا خير فيه ولا طائل تحته. والشريعة حين أقرت حق امتلاك الأموال من أجل الانتفاع بها دعت المالك إلى أن يمارس هذا الحق باعتدال وتوسط بعيداً عن السرف والخيلاء والتقتير. وفي الاعتدال في الإنفاق يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾^{٥١}، ويقول في آية أخرى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ

^{٤٨} القرطبي، يوسف بن عبد الله. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٧هـ، ص: ٨١١/٢. ابن جزى، محمد بن

أحمد الغرناطي. القوانين الفقهية. بيروت: عالم الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط، ص: ٣٢١

^{٤٩} الشيرازي، إبراهيم بن يوسف. المذهب. بيروت: دار الفكر، د. ط، ٣٧١/١. ابن قدامة، المغني، ٢٣٧/٥

^{٥٠} أحمد فرج حسين، النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه، ص: ٦٤

^{٥١} سورة الإسراء، آية: ٢٩

ذَلِكَ قَوَامًا^{٥٢}. فهذه الآيات تدل على أن الإنسان يكون وسطا في الإنفاق، لأن التقطير يؤدي إلى حبس المال ويحول دون نشاط التداول النقدي، وفي ذلك تعطيل لوظيفته. وأما التبذير والإسراف في ألوان الترف يولد في نفوس الفقراء الحقد والبغضاء، وفي ذلك خطر بالاجتماع ما بعده خطر. يقول تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا^{٥٣}﴾. والشريعة الإسلامية قد قررت مبدأ الحجر على الشخص الذي لا يحسن التصرف في أمواله استعمالا واستغلالا وإنفاقا أو يسبب في تصرفه ضررا للغير، فممنعه من التصرف وأناطت ذلك بوليّه أو وصيه في حالات معينة واقتصرت على منعه من التصرف في حالات أخرى.^{٥٤}

وبضرورة استثمار المالك لأمواله وعدم جواز تعطيلها. وذلك لأن الإسلام يحث أصحاب الأموال على تنميتها بالطرق المشروعة وعدم تعطيلها، لأن تعطيل المال يؤدي إلى فقر صاحبه، وبالتالي إلى فقر المجتمع، والإسلام يحارب الفقر ويغضه. ومن مظاهر الحث على ضرورة استثمار الأموال: الحث على العمل، ومباشرة مرافق الإنتاج المختلفة التي تحتاجها الأمة، وإعداد القوة، وفريضة الزكاة، ومنع تعطيل الأرض دون استغلالها في أراض الإقطاع والإحياء.

وبأن لا يكون في الاستعمال ضرر بالغير. وذلك لأن الإسلام أعطى المال للإنسان وجعل له حق استعماله، ولكنه قيّد هذا الاستعمال ألا يضر بأحد، لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار".^{٥٥} إن المال من الضروريات الخمس التي اجتمعت الشرائع السماوية على وجوب حفظها وقررت احترامها وحرمتها. وقد كفل الإسلام حرية الملكية بأحكام شرعها فجعل التراضي والرضا أساسا للمبادلات المالية. هذا هو الأصل، ولكن هناك أحوال استثنيت من هذا الأصل فتزول الملكية جبرا عن المالك، وذلك في حالة الضرورة مثل إذا دعت إلى ذلك مصلحة عامة، كإنشاء الطرق والمصارف وتوسيع دور العبادة ونحو ذلك، فإنه في مثل هذه الحالات

^{٥٢} سورة الفرقان، آية: ٦٧

^{٥٣} سورة الإسراء، آية: ١٦

^{٥٤} عدنان خالد التركماني، ضوابط الملكية في الفقه الإسلامي، ص ١٤٢-١٤٣

^{٥٥} رواه الإمام مالك في موطأه، كتاب الأقضية، حديث رقم: ١٢٣٤.

يجوز نزع الملكية إذا أبى المالك بيعها، أو إذا كان على المالك دين لآخر وامتنع عن أدائه. ففي هذه الحالة يجوز بيع أمواله جبراً لسداد ديونه، أو إذا احتكر شخص أو فئة من الناس الطعام وامتنعوا عن بيعه، فإن الحاكم يبيعه جبراً عن صاحبه.

الخاتمة

وتلخص من خلال العرض السابق أن الإسلام قد جاء بنظامٍ كاملٍ ومتكاملٍ تسيّر معاملات الناس عليه بشكل صحيح، وتستقيم الحياة الإنسانية بهذا النظام حيث لا يكون هناك ظلمٌ واعتداءٌ فيما بينهم. ولأجل أن حبَّ التملك غريزةٌ في الإنسان، وفطرةٌ فطر الله الإنسان عليها، وأن المال هو محور النشاط الاقتصادي في كل مجتمع وحجر الزاوية في بنيانه الاجتماعي، فقد تناول الإسلام موضوع الملك من كافة جوانبه، فنظّمه تنظيمًا دقيقًا حتى لا يتعدى أصحاب الملكية ولا يتعدى أحدٌ عليهم. ولما كان لبيان موضوع الملكية أهمية كبرى في الفقه الإسلامي، فقد وردت تفاصيل حول الملكية من خلال تعريفها، أنواعها، خصائصها وأسبابها - المشروعة وغير المشروعة-. وتلخص من ذلك أن الملكية أنواعٌ، منها تامّةٌ وناقصةٌ، خاصّةٌ وعامّةٌ، متميز وشائع. ففي الملكية التامة أسبابها وخصائصها، وكذا الناقصة.

لقد أباح الإسلام أخذ أنواع وسائل الكسب والتملك التي لم يرد فيها نهي أو تحرّم من الشرع، وذلك من خلال أسباب الملكية المشروعة مثل: حيازة المباح، العقود الناقلة للملكية، الإرث، والشفعة. وفي جانب آخر نهى الإسلام عن أسباب الملكية غير المشروعة. فحرّم كل الوسائل المؤدية إلى الغش، والخداع، والظلم، وما يسبّب الفوضى وعدم الاستقرار في المجتمع، مثل البيوع التي فيها غرر وجهالة، والسرقه، وقطع الطريق، والربا وما إلى ذلك من معاملات غير شرعية.

ولأجل المحافظة على صلاح المجتمع في معاملاتهم، وإزالة الضرر من الناس في مصالحهم الدنيوية والأخروية فيما يتعلق بحق التملك، فقد وضع الإسلام قيوداً على أسباب هذا التملك. ومن هذه القيود: إحسان الانتفاع والتصرف في الأموال، ضرورة استثمار المالك لأمواله وعدم جواز تعطيلها، وعدم استعمال الملكية لإضرار الغير. ولأجل حفظ المصالح العامة أقرّ الإسلام جواز نزع الملكية الخاصة جبراً في حالة الضرورة. وبهذا يُعرف العدل الإلهي في تحقيق مصالح العباد.

البيع: تعريفه، أركانه شروطه وأقسامه

تعريف البيع:

تعريف البيع:

البيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء؛ فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعاً لغة كمقابلتها بالنقد، ويقال لأحد المتقابلين: مبيع، وللآخر: ثمن.

وقال بعض الفقهاء: إن معناه في اللغة تمليك المال بالمال، وهو بمعنى التعريف الأول.

وقال آخرون: إنه في اللغة إخراج ذات عن الملك بعوض، وهو بمعنى التعريف الثاني؛ لأن إخراج الذات عن الملك هو معنى تمليك الغير للمال، فتمليك المنفعة بالإجارة ونحوها لا يسمى بيعاً.

أما الشراء فإنه إدخال ذات في الملك بعوض، أو تملك المال بالمال، على أن اللغة تطلق كلياً من البيع والشراء على معنى الآخر، فيقال لفعل البائع: بيع وشراء، كما يقال ذلك لفعل المشتري، ومنه قوله تعالى ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ﴾ [يوسف: 20]، فإن معنى ﴿شَرَوْهُ﴾ في الآية: باعوه، وكذلك الاشتراء والابتياح فإنهما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة.

إلا أن العُرف قد خص المبيع بفعل البائع، وهو إخراج الذات من الملك، وخص الشراء والابتياح بفعل المشتري، وهو إدخال الذات في الملك.

حكمه ودليل مشروعيته:

مشروعية البيع:

إن مشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

في الكتاب: ورد في القرآن الكريم ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ البقرة. [275] :

وفي سورة النساء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء. 29] :

وقوله تعالى ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ البقرة. [282] :

فهذه الآيات صريحة في حلّ البيع، وإن كانت مسوقة لأغراض أخرى غير إفادة الحل؛ لأن الآية الأولى مسوقة لتحريم الربا، والثانية مسوقة لنهي الناس عن أكل أموال بعضهم بعضاً بالباطل، والثالثة مسوقة للفت الناس إلى ما يرفع الخصومة، ويحسم النزاع من الاستشهاد عند التبايع.

في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر البيع، وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء، فأقرهم ولم ينههم عنه.

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح سواءً بسواء، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ رواه مسلم، فقوله: فبيعوا كيف شئتم صريح في إباحة البيع.

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل الرجل بيده؛ رواه أحمد والطبراني وغيرهما، والبيع المبرور هو الذي يبر فيه صاحبه فلم يغش ولم يُخن ولم يعص الله فيه، وحكمه حل ما يترتب عليه من تبادل المنافع بين الناس، وتحقيق التعاون بينهم.

الإجماع: وقد أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك.

كما أن الحكمة تقتضيه؛ لأن الحاجة ماسة إلى شرعيته؛ إذ الناس محتاجون إلى الأعواض والسلع، والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم، ولا طريق لهم إليه إلا بالبيع والشراء.

أركان البيع:

حدد القرآن الكريم أركان البيع كما أمر بها الله سبحانه وتعالى ليكون البيع حلال في الإسلام وتلك الأركان هي :
العاقدان: وهما البائع والمشتري.

الصيغة : وتنقسم إلى الصيغة الفعلية بإعطاء السلعة للمشتري، والصيغة القولية بالإيجاب من البائع باللفظ، والقبول من المشتري، أي تشترط ألفاظاً واضحة للبيع والموافقة بين كلا الطرفين، ويشترط في الصيغة أن تكون بألفاظ معينة مشتقة من لفظ باع أو مَلَكَ.

المعقود عليه : تشمل الثمن والشيء المثلث أو المبيع.

شروط البيع:

أ - التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين؛ منعاً من الوقوع في ربا النسيئة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
الذهب بالذهب مثلاً بمثل، يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، يداً بيد

ب - التماثل عند اتحاد الجنس: إذا بيع الجنس بالجنس، كفضة بفضة أو ذهب بذهب، فلا بد فيه من التماثل؛ أي :
التساوي في الوزن والمقدار دون النظر إلى الجودة والصياغة .

ج - أن يكون العقد باتاً، وألا يكون فيه خيار الشرط؛ لأن القبض في هذا العقد شرط، وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك أو تمامه، كما عرفنا.

د - التنجيز في العقد، وألا يكون فيه أجل؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يؤخر القبض.
فإذا اختلف شرط من هذه الشروط، فسد الصفقة.

أقسام البيع:

أولاً: تقسيم البيع باعتبار المبيع:

ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى أربعة أقسام:

- 1- البيع المطلق: هو مبادلة العين بالنقد، وهو أشهر الأنواع، ويتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه من الأعيان، وينصرف إليه البيع عند الإطلاق، فلا يحتاج كغيره إلى تقييد.
- 2- بيع السِّلَم: ويسمى السِّلَف، هو مبادلة الدين بالعين، أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل.
- 3 - بيع الصرف: وهو بيع جنس الأثمان بعبئه ببعض، وعرف بأنه بيع النقد بالنقد جنسًا بجنس، أو بغير جنس؛ أي: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وكذلك بيع أحدهما بالآخر.
- وإنما يسمى صرفًا: لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس.
- 4- بيع المقايضة: وهو مبادلة مال بمال سوى النقدين، ويشترط لصحته التساوي في التقابض إن اتفقا جنسًا وقدرًا، فيجوز بيع لحم بشاة حية؛ لأنه يبيع موزون بما ليس بموزون، وخبز بدقيق متفاضلاً؛ لأنه يبيع مكيل بموزون.

ولا يجوز بيع التين الرطب بالتين اليابس إلا تماثلًا، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق أو البرغل مطلقًا ولو متساويين؛ لانكباس الأخيرين في المكيال أكثر من الأول، أما إذا يبيع موزونًا فالتماثل واجب.

ثانيًا: تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن:

ينقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى ثلاثة أنواع:

- 1- بيع المساومة: هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس ماله؛ أي: البيع بدون ذكر ثمنه الأول.
- 2- بيع المزايمة: هو أن يعرض البائع سلعته في السوق، ويتزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الثمن أكثر.
- 3- بيع الأمانة: هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال، أو أزيد أو أنقص، وسميت ببيع الأمانة؛ لأنه يؤمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع:

- أ - بيع المراجعة: وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع، مع زيادة ربح معلوم متفق عليه.
- ب - بيع التولية: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به، من غير نقص ولا زيادة.
- ج - بيع الوضعية: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به، مع وضع حط مبلغ معلوم من الثمن؛ أي: بخسارة محددة.

هذا، وفي حالة كون البيع يتم لجزء من المبيع، فإنه يسمى بيع الاشتراك، وهو لا يخرج عن الأنواع المتقدمة المذكورة من البيوع.

ثالثًا: تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن:

- 1- بيع منجز الثمن :وهو ما يشترط فيه تعجيل الثمن، ويسمى بيع النقد، أو البيع بالثمن الحال.
- 2- بيع مؤجل الثمن :وهو ما يشترك فيه تأجيل الثمن.
- 3- بيع مؤجل المثلث :وهو مثل بيع السلم وبيع الاستصناع.
- 4- بيع مؤجل العوضين :أي بيع الدين بالدين، وهو ممنوع في الجملة.

رابعًا: تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي:

ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع كثيرة، منها:

- 1 - البيع المنعقد، ويقابله البيع الباطل.
- 2 - البيع الصحيح، ويقابله البيع الفاسد.
- 3- البيع النافذ، ويقابله البيع الموقوف.
- 4- البيع اللازم، ويقابله البيع غير اللازم، ويسمى الجائز أو المخير.

الخيار: تعريفه وأقسامه وأحكامه

الخيار لغة: الخيار اسم مشتق من (الاختيار) وهو الاصطفاء والانتقاء، والفعل منهما (اختار). وقول القائل: أنت بالخيار، معناه اختر ما شئت. وخيره بين الشيئين معناه: فوّض إليه اختيار أحدهما. والخيار في البيع هو اصطفاء خير الأمرين إمضاء البيع أو فسخه.

الخيار اصطلاحاً: الخيار في الاصطلاح الفقهي له تعريف كثيرة، إلا أنها في الغالب تناولت هذا اللفظ مقروناً بلفظ آخر لأنواع الخيارات دون أن يقصد بالتعريف الخيار عموماً. ويمكن من تعريف أنواع الخيار استخلاص تعريف للخيار بأن يقال: هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوّغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي.

الحكمة منه

الأصل في عقد البيع أنه إذا وجدت أركانه وتحققت شروطه أن ينعقد مبرماً بحيث تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع، إلا أن الشارع راعى مصالح المكلفين فشرع الخيارات رحمة بالمتعاقدين لضمان رضاها وحفظ مصلحتهما ودفع الضرر عنهما، ومن أجل نفي المنازعات والخصومات وذلك من أهم مقاصد الشريعة، وكذلك من أجل تحقيق العدل ومنع الظلم في المعاملات والوصول إلى تمام الرضا والتوسعة على العاقدين.

الخيارات المشروعة: أوصل الفقهاء الخيار إلى ما يقارب العشرين نوعاً أهمها خمسة وهي:

- 1- خيار المجلس.
- 2- خيار الشرط.
- 3- خيار العيب.
- 4- خيار الرؤية
- 5- خيار التدليس

وفيما يلي تفصيل الكلام عنها:

أولاً: خيار المجلس:

ويكون خيار المجلس حق للشخصين المتبايعين ، فان تفرقا لزم البيع ، وان أسقطاه سقط البيع ، وان قام احد الشخصين بإسقاطه بقي خيار للآخر ، أما عن مدته فتكون من خلال جلسة العقد ويسقط الخيار عند التفرقة ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتَزَكَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»

ثانياً: خيار الشرط:

تعريفه: وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كل منهما أن له الخيار -أي حق فسخ العقد أو إمضائه - خلال مدة معلومة.

• ويمكن أن يشترط ذلك مع العقد، ويمكن أن يشترط بعده ولكن قبل مفارقة مجلس التعاقد.

• وسمي خيار الشرط لأن سببه اشتراط العاقد.

حكمته:

شُرِعَ للحاجة إليه، ولدفع الغبن والضرر عن العاقد في البيوع.

دليله:

أن حَبَّانَ بن منقذ الأنصاري كان يُغبن في البياعات بسبب ضربة سيف أصابت رأسه فثقل بذلك نطقه وضعف إدراكه، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا بايعت فقل: لا خلافة، وفي رواية: ولي الخيار ثلاثة أيام أخرجه البخاري، والخلافة: هي الخديعة أو الخداع، والحديث: المسلمون على شروطهم.

حكمه:

قال بجواز خيار الشرط جماهير العلماء، ولكنهم اختلفوا في مدته.

• فقال الحنفية والشافعية: لا تزيد مدة الخيار على ثلاثة أيام لأنه نص الحديث، ولأن الحاجة تتحقق بذلك غالباً، فإذا زاد على ذلك بطل العقد عند الشافعية وقيد عند أبي حنيفة.

• وقال الحنابلة والصاحبان: مدة الخيار بحسب الاتفاق بين المتعاقدين ولو زادت على ثلاثة أيام؛ لأن الخيار مشروع للتروي والمشورة وقد لا تكفي لها هذه المدة، والتحديد الوارد في الحديث قالوا إنه خاص بجهان لأنه كان يكفي ذلك.

• وقال المالكية: يجوز الخيار بقدر ما تدعو إليه الحاجة وتختلف باختلاف الأموال، فالفاكهة خيارها لا يزيد على اليوم لأنها تفسد، والثياب والدواب ثلاثة أيام، والدور شهر...

متى يسقط خيار الشرط:

ينتهي خيار الشرط بواحد من الأمور التالية:

- 1- إتمام العقد أو فسخه مدة الخيار بالقول أو الفعل.
- 2- بانتهاء المدة المشروطة دون إجازة أو فسخ: لزم العقد وسقط الخيار.
- 3- هلاك المبيع أو تعيبه الظاهر في يد صاحب الخيار: فإن كان الخيار للبائع بطل البيع، وإن كان للمشتري لزم البيع.
- 4- موت صاحب الحق في خيار الشرط، وهذا عند الحنفية والحنابلة؛ لأن خيار الشرط عندهم لا يورث، وقال المالكية والشافعية: لا يسقط الخيار بالموت بل ينتقل إلى الورثة؛ لأنه حق متعلق بالمال وهو المعقود عليه، والحقوق المالية تورث لحديث: من ترك مالا أو حقا فلورثته أحمد وغيره.

ثالثًا: خيار العيب:

الأصل في تعامل المسلم مع غيره النصح وعدم الغش؛ لأن في الغش أكلاً لأموال الناس بالباطل، كما حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من الغش أشد تحذير حين قال: من غش فليس منا أخرجه مسلم.

تعريف خيار العيب:

هو أن يكون لأحد المتعاقدين الحق في منع العقد أو إمضائه إذا وجد عيباً في أحد البديلين.

كأن يجد الحيوان الذي اشتراه مريضاً، أو السيارة معطلة وبها عيب.

دليله:

سبب ورود الحديث السابق، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرّ في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟، قال: يا رسول الله، أصابته السماء، فقال: ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني مسلم.

وحديث: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بيّنه له ابن ماجه. ويلحق غير المسلم به استدلالاً لعموم الأحاديث، ولأن الأخلاق في الإسلام أخلاق ذاتية إنسانية، يجب التخلق بها مع المسلم وغيره.

ويستدل لخيار العيب بحديث المصراة الذي سبق، وكذلك يستدل لهذا بالمعقول: فإن الأصل في البيع أنه على شرط السلامة، وأن المشتري ما بذل كامل الثمن إلا ليسلم له كامل المبيع لتحصل المقابلة بين الثمن والمثمن وتلك رغبة المشتري الذي رضي بالبيع، فإذا اختل شيء من ذلك بسبب العيب فقد فات مقصوده ولم يتحقق رضاه، فثبت له حق الفسخ ورد المبيع واسترداد الثمن.

شروط ثبوت خيار العيب:

1- أن يثبت أن العيب قديم وليس بحادث.

2- أن يكون العيب منقصاً لقيمة المبيع في عرف التجار.

متى يكون الرد بخيار العيب: يثبت خيار العيب بمجرد ظهور العيب ولو بعد العقد بمدة طويلة، أما وقت فسخ العقد بعد العلم ففيه رأيان للفقهاء:

أ - المالكية والشافعية قالوا يجب الفسخ فوراً بعد العلم بالعيب حتى لا يلحق الضرر بالبائع بسبب التأخير، فإذا تأخر المشتري بما يعتبر تراضياً سقط حقه في ذلك.

ب - الحنفية والحنابلة: قالوا خيار العيب على التراخي، فلا يسقط حتى يوجد منه ما يدل على الرضا؛ لأن هذا الخيار شرع لدفع الضرر فلا يبطل بالتأخير.

حكم العقد المشتتم على خيار العيب: حكمه اللزوم والإمضاء فيلزم تملك العاقدین للبديلين، إلا أنه ثبت لمن له الخيار الحق في الرد إن شاء، وإن شاء رضي بالمعقود عليه كما هو، ولكن اختلف الفقهاء فيما إذا أراد الاحتفاظ بالمعقود عليه والمطالبة بفرق النقصان بسبب العيب، والراجح أنه لا حق له ما دام الرد ممكناً إلا إذا تراضيا على ذلك.

هل يحتاج الفسخ إلى حكم القاضي؟

قال الحنفية: لا يفسخ العقد إلا بالتراضي أو حكم القاضي.

وقال الشافعية والحنابلة: ينفسخ العقد بقول صاحب الخيار: "رددت" بغير حاجة إلى التراضي أو حكم الحاكم.

شرط البراءة من العيوب: اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، والراجح -والله أعلم- أن شرط البراءة من العيب يصح في كل عيب لا يعلم به البائع، أما ما يعلم به فلا يصح البراءة منه.

رابعاً: خيار الرؤية:

تعريفه: هو إثبات حق المشتري في إمضاء العقد أو فسخه عند رؤية المعقود عليه إذا لم يكن رآه عند العقد أو قبله.

دليله: حديث: من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه -الدارقطني، وقال عنه: باطل-، واستدلوا له بما روي أن سيدنا عثمان باع أرضاً له من طلحة لم يكونا رآياها، فقبل لعثمان: غبنت، فقال: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره، فحكّمنا في ذلك جبير بن مطعم فقضى بالخيار.

ولقد اختلف العلماء في الأخذ به فقال به الجمهور وخالف في ذلك الشافعية، وقال الشافعي: لا ينعقد بيع الغائب أصلاً سواء كان بالصفة أم بغير الصفة، ولا يثبت خيار الرؤية لأن في العقد غرراً وجهالة، ولأن الحديث المستدل به ضعيف.

لمن يثبت خيار الرؤية؟

يثبت الخيار للمشتري عند رؤية المبيع، لا قبلها، ولو أجاز العقد قبل الرؤية لم يلزم العقد ولا يسقط الخيار، أما لو فسخ قبل الرؤية صح الفسخ لا من أجل الخيار ولكن لأن العقد يصير غير لازم.

بيع الأنموذج: الأشياء التي تباع على حسب أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها، فإن تبين أن البيع دون الأنموذج يكون مخيراً بين قبوله بالثمن المسمى أو رده.

وحكمه أنه يجوز عند الجمهور، ولا يجوز عند الحنابلة والظاهرية لأنه يشترط عندهم رؤية مقارنة للبيع وذلك برؤية جميع المبيع.

أثر خيار الرؤية:

• قال الحنفية: يكون العقد غير لازم لمن ثبت له الخيار، فيخير بين الإمضاء والفسخ عند رؤية المعقود عليه سواء وجده مطابقاً أو مخالفاً للموصوف.

• وقال الحنابلة والمالكية: إذا أثبتت الرؤية أن المعقود عليه مطابق للموصوف يكون العقد لازماً للمشتري، وإذا كان مخالفاً للموصوف ثبت له الخيار وهو الراجح.

وهناك أنواع أخرى من الخيارات بعضها داخل في بعض ما تقدم، نوجزها فيما يلي:

خامساً: خيار التدليس:

وهو أن يقوم البائع بتدليس السلعة على المشتري ، ويقوم بزيادة سعرها فهنا يحق للمشتري فسخ العقد ، ويعتبر هذا فعل محرم لما به من غش وخداع ، لذلك إذا يقع الخيار بين الإمساك أو الفسخ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تُصَرُّوا الْعَنَمَ ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْتَلِبَهَا : إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ . » متفق عليه

المراجع المساعدة:

- 1-بدائع الصنائع. (5/228)
- 2 -القوانين الفقهية. (164)
- 3-مغني المحتاج (2/30)،. (94)
- 4-كشاف القناع. (3/180-236)
- 5 -الفقه الإسلامي وأدلته. (4/519-522)
- 6-المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. (377-381)
- 7-ضوابط العقد في الفقه الإسلامي. (266-292)
- 8 -الملكية ونظرية العقد، محمد أبو زهرة. (420-461)

17- المساقاة والمزارعة

- **المساقاة:** هي دفع شجر له ثمر إلى آخر ليقوم بسقيه بجزء معلوم مشاع من ثمره كالربع أو النصف ونحوهما، والباقي للمالك.
- **المزارعة:** هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف أو الربع ونحوهما، والباقي لمالك الأرض.
- **فضل المساقاة والمزارعة:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ». متفق عليه⁽¹⁾.

● **حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة:**

الله عز وجل قسم الأرزاق والطاقات بين الناس، فمن الناس من يملك الأرض والشجر، أو يملك الأرض والحب، ولكنه لا يستطيع سقيها والعناية بها، إما لعدم معرفته، أو لانشغاله، أو لعدم قدرته، ومن الناس من يملك القدرة على العمل، لكنه لا يملك الأرض والشجر. فلمصلحة الطرفين أباح الإسلام المساقاة والمزارعة؛ عمارة للأرض، وتنمية للثروة، وتشغياً للأيدي العاملة التي تملك القدرة على العمل، ولا تملك المال والشجر.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2320)، ومسلم برقم (1553).

● حكم المساقاة والمزارعة:

1- تجوز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الزرع والثمر كالنصف أو الربع ونحوهما.

والمساقاة والمزارعة عقد لازم، لا يجوز فسخهما إلا برضاهما.

عَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. متفق عليه⁽¹⁾.

2- لا تجوز المساقاة والمزارعة إذا كان النصيب معيناً من الثمر أو الزرع كالذي على الجداول أو السواقي، أو يحدد بقعة معينة من الزرع، أو نخلاً أو شجراً معيناً، أو يقول المالك هذه الجهة لي، وهذه الجهة لك، فهذه مزارعة ومساقاة مجهولة؛ لأنه لا يعلم عاقبة الأمر، فربما صح هذا، وتلف هذا، فمُنِعَ من أجل جهالته وخطره، وهذه المزارعة تسمى المخابرة.

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلُمُ هَذَا، وَيَسْلُمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ رُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. أخرجه مسلم⁽²⁾.

وهذه المزارعة فاسدة ممنوعة، منهي عنها.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2328)، ومسلم برقم (1551)، واللفظ له.

(2) أخرجه مسلم برقم (1547).

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ
الْمُزَارَعَةِ. أخرجه مسلم⁽¹⁾.

● حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة:

يجوز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على
الشجر بجزء معلوم مشاع من الثمرة، ويزرعه الأرض بجزء معلوم
مشاع من المزروع.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا
يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. متفق عليه⁽²⁾.

● شروط المزارعة:

يشترط لصحة المزارعة ما يلي:

- 1- أهلية العاقدین ورضاهما.
- 2- صلاحية الأرض للزراعة.
- 3- تسليم الأرض للعامل.
- 4- بيان مَنْ عليه البذر منعاً للنزاع.
- 5- بيان نصيب كل من العاقدین بجزء مشاع كالنصف أو الربع ونحوهما.
- 6- معرفة جنس البذر وقدره.

● أحوال المزارعة:

للمزارعة أربعة أحوال هي:

(1) أخرجه مسلم برقم (1549).

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2329)، واللفظ له، ومسلم برقم (1551).

- 1- أن تكون الأرض والبذر من واحد، والعمل وآلة العمل من واحد.
 - 2- أن تكون الأرض لواحد، والبذر والعمل وآلة العمل من واحد.
 - 3- أن تكون الأرض والبذر وآلة العمل لواحد، والعمل من واحد.
 - 4- أن تكون الأرض وآلة العمل كالحراثة لواحد، والعمل والبذر من واحد.
- وكل هذه الصور جائزة بين الطرفين متى حصل التراضي، وانتفى
الجهل والغرر والضرر.

● ما يجوز به إجارة الأرض:

تجوز إجارة الأرض بالنقود.. وبالذهب والفضة.. وبجزء معلوم مشاع
مما يخرج منها من ثمر، أو زرع كالنصف، أو الربع ونحوهما.. وبكل
ما يعد مالاً.

- 1- عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ فَقَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ؟ فَقَالَ:
أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. أخرجه مسلم⁽¹⁾.
- 2- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى خَبِيرَ الْيَهُودِ،
عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. متفق عليه⁽²⁾.

● حكم المساقاة والمزارعة مع الكفار:

المساقاة والمزارعة من عقود المعاوضة التي تجوز مع المسلم والكافر
بشروطها الشرعية المعتمدة.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى

(1) أخرجه مسلم برقم (1547).

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2331)، واللفظ له، ومسلم برقم (1551).

يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَغْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 وَلِرَسُولِهِ ﷺ شَطْرُ نَمْرُهَا. متفق عليه⁽¹⁾.

● عقوبة التوسع في الأعمال:

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئاً مِنْ آلَةِ
 الْحَرْثِ- فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ
 اللَّهُ الدَّلَّ». أخرجه البخاري⁽²⁾.

● فضل المواساة في المزارعة:

الأفضل للمسلم مواساة أخيه المحتاج، فإذا ملك أرضاً وهو لا يريد أن
 يزرعها فالأحسن أن يعطيها لأخيه ليزرعها وله أجرها وثوابها.

1- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ،
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ
 يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ». متفق عليه⁽³⁾.

2- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَرُ
 زَرْعاً، فَقَالَ: «لِمَنْ هَذِهِ؟». فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ، فَقَالَ: «أَمَّا إِنَّهُ لَوْ
 مَنَحَهَا إِيَّاهُ، كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْراً مَعْلُوماً». متفق عليه⁽⁴⁾.

● صفة الزراعة في الجنة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ، وَعِنْدَهُ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2285)، ومسلم برقم (1551)، واللفظ له.

(2) أخرجه البخاري برقم (2321).

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2340)، واللفظ له، ومسلم برقم (1536).

(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2634)، واللفظ له، ومسلم برقم (1550).

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أَحْبُّ أَنْ أَزْرَعَ، قَالَ: فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتَوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ». أخرجه البخاري⁽¹⁾.

● حكم المغارسة:

المغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجراً أو نخلاً، ويكون للعامل نصيب مقدر من الأرض والشجر كالربع والنصف ونحوهما.

وهي جائزة إذا حصل التراضي، وانتفى الجهل والغرر.

● حكم بيع المحاقلة والمخاضرة والمخابرة:

1- المحاقلة: بيع الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جنسه مُصْفًى.

وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والربا.

2- المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها مع عدم القطع في الحال.

وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والغرر.

3- المخابرة: هي أن يكري الأرض، ويكون لصاحب الأرض جانب معين من الزرع، وللمزارع الجانب الآخر.

وهذه هي المزارعة الفاسدة، وهي محرمة؛ لما فيها من الجهالة والضرر.

(1) أخرجه البخاري برقم (2348).



- 1- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ النَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالذِّينَارِ وَالذِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا. متفق عليه⁽¹⁾.
- 2- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمَلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. أخرجه البخاري⁽²⁾.

● حكم منع فضل الماء:

يجب على المسلم إذا استغنى عن بعض الماء أن يعطيه لأخيه المحتاج. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِمَنْعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَاءِ». متفق عليه⁽³⁾.

● فضل سقي الماء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاسْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ». متفق عليه⁽⁴⁾.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2381)، واللفظ له، ومسلم برقم (1536).

(2) أخرجه البخاري برقم (2207).

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2354)، واللفظ له، ومسلم برقم (1566).

(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2363)، واللفظ له، ومسلم برقم (2244).

● **حكم من منع ابن السبيل الماء:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظَرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخَطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَا الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ». ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: (ثُمَّ تَوَلَّى تَوَلَّى) . متفق عليه^(١).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2358)، واللفظ له، ومسلم برقم (108).

المضاربة: تعريفها، حكمها، أركانها، وشروطها. المراجعة والمصرفية.

تعريف المضاربة:

المضاربة اسم مشتق من الضرب في الأرض، بمعنى السفر و هو من مستلزمات التجارة، قال تعالى: « وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. »

و قد عرفها الحنفية بأنها ” عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب ” و عرفها الحنابلة بأنها ” دفع مال إلى آخر يتجر به والربح بينهما ”، أما المالكية فقالوا بأنها ” أن يعطي الرجل المال على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال. ”

المضاربة إذن شركة في الربح بمال من جانب يسمى رب المال و عمل من جانب آخر يسمى المضارب . و تسمى المضاربة أيضا ”قراضا .“

أركان المضاربة: هي

- 1-الإيجاب والقبول أي الصيغة.
- 2-رب المال
- 3-العامل: المضارب
- 4- رأس المال
- 5-الربح، و بعضهم لا يعتبره من أركان المضاربة لأنه من النتائج المحتملة.

مشروعية المضاربة

و فيما يخص مشروعية المضاربة ,فقد جاء في السنة أن الرسول عليه الصلاة و السلام قد خرج قبل بعثته مضاربا في مال أمنا خديجة رضي الله عنها . كما أن العمل استمر بهذا العقد بعد بعثة النبي صلى الله عليه و سلم ,و كذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم.

فلا خلاف بين الفقهاء على مشروعية المضاربة و جوازها و أنها كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام , فقد قال ابن عبد البر رحمه الله ”: و القراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم , و كان في الجاهلية فأقره الرسول صلى الله عليه و سلم في الإسلام.”

شروط المضاربة

إضافة إلى الشروط العامة المطلوبة في أي عقد مثل الإيجاب والقبول و العاقدان و الصيغة... هناك مجموعة من الشروط لا بد أن تتوفر حتى يكون عقد المضاربة ناجحا من ناحية استثمارية و مقبولا كذلك من ناحية شرعية . و يمكن تقسيم هذه الشروط الى ثلاثة أقسام , فهناك الشروط المتعلقة برأس المال و تلك المتعلقة بالربح وأخيرا الشروط المتعلقة بالعمل.

أولا : شروط رأس المال

- 1- أن يكون رأس المال نقودا . و قد أجاز بعض الفقهاء أن يكون سلعا أو عقارا , أو كالأثرية تقدم لشركة طيران تستغلها و يتم قسمة العائد , أو أن يقول مالك السلعة أو العقار للمضارب بعها وضارب في الثمن , و بالتالي يكون وكيلا في بيعها ثم مضاربا في ثمنها بعد قبض مبلغ البيع.
- 2- أن يكون رأس المال معلوم القدر و الجنس و الصفة عند التعاقد.
- 3- أن لا يكون دينا في ذمة المضارب.
- 4- تسليم رأس المال الى المضارب و تمكينه ماديا و قانونيا من التصرف فيه حتى يتمكن من استثماره و توضيفه وفقا للعقد.

ثانيا : شروط الربح

- 1- أن تكون نسبة كل من المضارب و رب المال في الربح معلومة عند التعاقد.
- 2- أن يكون نصيب كل منهما جزءا شائعا من الربح , و ليس من رأس المال.
- 3- أن يكون نصيب كل منهما حصة في الربح , لا حصة في رأس المال.
- 4- أن لا يزداد على حصة أي من الطرفين في الربح منفعة اضافية , كأن يشترط المستثمر الذي يحصل على تمويل من البنك الاسلامي الحصول على خدمات مصرفية مدفوعة بالمجان.

5- الخسارة يتحملها رب المال إذا لم تكن بسبب تقصير المضارب أو مخالفته لشروط العقد، وأما في حالة العكس فإنه يشترك في هذه الخسارة. فإذا كان البنك الاسلامي هو المضارب فمن الواجب عليه المحافظة على أموال المودعين.

ثالثا: شروط العمل

- 1- العمل من اختصاص المضارب وحده، فصاحب المال مهمته هي تقديم المال و ليس العمل.
- 2- يجوز لصاحب المال أن يشترط على المضارب بأن يمارس عمله في بلد معين ، أو نوع معين من السلع أو في العمل الذي يكون فيه مصلحة الطرفين دونما تضيق على المضارب، وهذا ما يعرف بالمضاربة المقيدة.
- 3- أن يكون العمل مشروعاً مما تجوز فيه المضاربة و حسب شروط عقد المضاربة، فيجوز مثلاً للمضارب العمل في التجارة و ما ينتج عنها كالرهن و الإيجار و تأخير الثمن إلى أجل متعارف عليه، إلا إذا نص العقد على عدم القيام بأحد الأعمال السابقة . كما لا يجوز للمضارب أن يقرض مال المضاربة أو الهبة والصدقة من مال الضريبة.
- 4- للمضارب أن يدفع المال مضاربة الى غيره ، و ان يخلط مال المضاربة بمال غيره إذا أطلق صاحب المال يده في التصرف.
- 5- يجوز للمسلم أن يأخذ المال مضاربة من غير المسلم، فلا يشترط في رب المال أن يكون مسلماً . و في حالة المضارب غير المسلم اشترط الفقهاء أن لا ينفرد وحده بالتصرف، أي تكون المضاربة مقيدة، لأن انفراد المضارب غير المسلم بالتصرف قد يؤدي إلى القيام بأعمال لا تتفق مع قواعد الشرع، ومن ثم تكون المضاربة المقيدة هي الخيار الأمثل.
- 6- لصاحب المال الحق في فسخ عقد المضاربة متى شاء ما لم يبدأ المضارب في العمل . أما إذا بدأ العمل فاختلف الفقهاء في حكم ذلك ، فالمالكية يرون أنه ليس لصاحب المال الحق في فسخ العقد بعد شروع المضارب في العمل ، في حين أن الشافعية و الحنفية و الحنابلة يرون جواز فسخ العقد لصاحب المال . و أما بالنسبة للبنك الإسلامي فإنه ليس له الحق في فسخ العقد لأنه قبل الموافقة يكون قد درس المشروع، إلا في حالة ما إذا كان هناك مشروع أولى منه وهذا إذا لم يكن المضارب قد شرع في العمل.

أنواع المضاربة

يمكن تقسيم المضاربة في البنوك الإسلامية إلى ثلاثة أقسام رئيسية :

أولا : حسب حرية المضارب في التصرف

1- المضاربة المطلقة: للمضارب في هذا النوع الحرية المطلقة في استثمار المال كيفما يشاء دون قيد على قراراته أو تدخل من جانب رب المال . ويعتبر هذا النوع من المضاربة الشكل الغالب على عمل البنوك الإسلامية في مجال المضاربة، حيث يُترك للبنك الحرية الكاملة في توظيف أموال مودعيه في المجالات المناسبة.

2- المضاربة المقيدة: يضع رب المال في هذا النوع من المضاربة قيودا وشروطا معينة، سواء فيما يخص مجالات الاستثمار أو طريقة إدارة المال ومدة الاستثمار، و مكان الاستثمار أو الأشخاص الذين سيتعامل معهم . كما أنه لابد وأن يتم الاتفاق على هذه الشروط قبل إبرام عقد المضاربة أو على الأقل قبل صرف مال المضاربة في المشروع، و هذا ما يسمى في البنوك الإسلامية بالاستثمار المخصص.

تجدر الإشارة هنا إلى أن تقييد المضاربة أو إطلاقها يعتبر أمرا نسبيا , حيث لا يمكن إطلاق يد العامل بشكل كامل أو تقييد تصرفاته بالمال بشكل كامل , فكلما كانت الشروط أقرب للتقييد سميت المضاربة بالمقيدة وإذا كان العكس سميت بالمطلقة.

ثانيا : حسب كيفية انتهاء عقد المضاربة

1- المضاربة المنتهية بالتملك: نوع من المضاربة يعطي فيها رب المال الحق للمستثمر المضارب بالحلول مكانه في ملكية المشروع مرة واحدة أو على دفعات، وهي تشبه في خطواتها المشاركة المنتهية بالتملك.

2- المضاربة غير المنتهية بالتملك: وهو الوضع العادي حيث يعود رأس المال إلى المالك بعد انتهاء فترة الاستثمار وتوزيع الأرباح بين الأطراف المشاركة في المضاربة.

ثالثا :حسب عدد المشاركين

1-المضاربة الثنائية أو المفردة : وتعني وجود شخص واحد يقدم المال وشخص واحد يقوم بالعمل، أي أن العقد يكون بين طرفين سواء كانا طبيعيين أو اعتباريين .ويصعب استخدام هذا النوع من المضاربة في البنوك الإسلامية ,كون طبيعة عمل هذه الأخيرة تستلزم خلط ومزج أموال المضاربة ,أي خلط أموال البنك مع أموال المودعين.

2-المضاربة الجماعية أو المشتركة :هي الصيغة التعاقدية السائدة في البنوك الإسلامية ,حيث تعرض هذه الأخيرة باعتبارها مضاربا على أصحاب الأموال إستثمار مدخراتهم ,كما تعرض هذه البنوك (باعتبارها صاحب مال أو وكلاء عن أصحاب الأموال على رجال الأعمال أو أرباب التجارة استثمار أو تشغيل تلك الأموال، على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وتقع الخسارة على صاحب المال .و معظم الأموال التي تستثمر بهذه الطريقة في البنوك الإسلامية هي من الودائع الاستثمارية الثابتة و الودائع الإدخارية.

فالمضاربة المشتركة لها ثلاثة أطراف :صاحب رأس المال ,و البنك الاسلامي و المضارب ,في حين أن المضاربة الفردية لها طرفان :صاحب المال و المضارب المستثمر.

و يتم تنفيذ المضاربة المشتركة في البنوك الإسلامية عبر المراحل التالية:

-يتقدم أصحاب رؤوس الأموال بمدخراتهم بصورة فردية الى البنك الاسلامي ,و ذلك لإستثمارها لهم في المجالات المناسبة.

-يقوم البنك الاسلامي بدراسة فرص الإستثمار المتاحة و المرشحة للتمويل.

-يخلط البنك الاسلامي أموال أصحاب رؤوس الأموال و يدفع بها الى المستثمرين كل على حدة .و بالتالي تنعقد مجموعة شركات المضاربة الثنائية بين البنك الاسلامي و المستثمر.

-تحسب الأرباح كل سنة بناء على ما يسمى بالتنضيض التقديري-تسييل -أو التقويم لموجودات الشركة بعد حسم النفقات.

-توزع الأرباح بين الاطراف الثلاثة ,صاحب المال و البنك الاسلامي و المضارب.

و نظرا لكون المضاربة المشتركة تقوم على أساس الخلط المتلاحق لأموال المودعين مع بقاء الامور على حالها دون تنضيض أو تصفية للحساب , فينتج عن ذلك مشاركة المال اللاحق للمال السابق في الربح و الخسارة.

و التنضيض لفظ اصطلاحي للفقهاء يعني تحول جميع الأصول إلى نقود كما بدأت المضاربة . ويترتب على ذلك قبض رب المال المالك رأس المال كاملا , و لا يعتبر مقبوضا إلا إذا عاد إلى حالته الأولى التي اشترط توافرها ليصح جعله رأس مال للمضاربة , فيعود أثمانا دون بقاء أي شيء منه عروضاً أو ديونا في الذمة.

إن التنضيض سواء كان لرأس المال كله أو لجزء منه ليس إجراء للتوصل للحساب، بل هو أمر ضروري لإعطاء كل ذي حق حقه بالعدل و القسطاس لا بالجزاف و التخمين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتنضيض الذي تتحول به السلع و عروض التجارة إلى مال ناض، أي أثمان لا تحتل بعدئذ زيادة ولا نقصا.

و في هذا الصدد يقول الدكتور شبير ”:يمكن القول بجواز خلط أموال المضاربة بشرط الإذن الصريح أو التفويض العام , لأن الإنسان يملك التصرف في ماله بحجر خسارة شريكه . فلا إشكال في ذلك و ينبغي أن يراعى في توزيع الأرباح المدة الزمنية للوديعة.“

و يصار الى التنضيض التقديري في نهاية كل مدة مع الإستمرار في المضاربة المشتركة دون فسخ لها , فتوزع الأرباح في نهاية كل سنة و لو لم تنته المشاريع التي أسهم فيها البنك الإسلامي.

و التنضيض التقديري أمر جائز , حيث تقدر نسبة الأرباح في كل سنة بالنسبة الى رأس المال , و توزع على أصحاب الأموال بحسب مقدار كل مال و فترة إستثماره.

توقيت المضاربة

و بخصوص توقيت المضاربة , فهناك من أجاز توقيت عقد المضاربة بمعنى تحديد وقت لإنتهائها مثل الحنفية , و منهم من يرى عدم جواز ذلك مثل الشافعية و المالكية.

و الحنفية يميزون توقيت المضاربة لأن عقد المضاربة عقد توكيل ,و التوكيل يحتم التخصيص بوقت دون الآخر .و الملاحظ أن معظم البنوك الإسلامية قد أخذت برأي الأحناف في هذا المجال ,لكن الاخذ بهذا الرأي يجب ان يتم في ضوء ضوابط نذكر منها:

- أن يكون الوقت كافيا ليتمكن المضارب من العمل في المال ضمن الأصول و القواعد المعمول بها.
 - تحقيق مصلحة البنك الاسلامي و المودعين و المضاربين.
 - يفضل ان يكون التوقيت مع المضاربين التجار الذين يعملون في نفس مجال المضاربة ,بحيث يستطيع هؤلاء تصفية المضاربة عند إنتهاء الوقت دون أن يتأثروا سلبا بذلك.
- أما بخصوص حالة خروج أحد طرفي المضاربة ,أي الانسحاب من هذه المضاربة القائمة على رأس مال مشترك، فإن هذا الخروج مأذون به بحسب أنظمة البنك الإسلامي، فيكون المنسحب قد باع إلى شريكه أو شركائه الباقين ما يخصه من المشتريات التي لم تنض، و ذلك بنفس المبلغ الذي دخل به، و لا شيء يؤخذ على هذا التصرف فهو من يبيع الأمانة على سبيل التولية غالبا.

إنتهاء المضاربة

تنتهي المضاربة في الحالات الآتية:

- فسخ الشركة بإرادة أحد الطرفين أو كليهما.
- انتهاء أجلها.
- هلاك مال المضاربة.
- موت أحد الشريكين أو فقدانه أهليته،أو تصفية المؤسسة المضاربة
- عزل رب المال المضارب وكان المال ناضاً أي نقدا.

و في حال انتهاء المضاربة ومازالت ديونها قائمة فإن كان للمضارب ربح فإنه مجبر على تحصيله لأن هذا من عمله ,و لا يأخذ الربح ما لم يقيم بتصفية ديون المضاربة .أما إذا خسرت المضاربة فعلى المضارب أن يوكل صاحب رأس المال تحصيلها و لا يُجبر المضارب على تحصيلها.

و في ما يخص تكييف العلاقة مع البنك الاسلامي ,فهناك رأيان:

1. اعتبار البنك مضاربا ثم رب المال :أصحاب الودائع الاستثمارية بمجموعهم هم رب المال و البنك هو المضارب بطريق المضاربة المطلقة التي تتيح له أن يدفع المال بدوره إلى شخص آخر على سبيل المضاربة . وبما أن البنك الإسلامي يستعين لتنمية الأموال بأصحاب المشروعات الاستثمارية فيقدم إليهم الأموال فهو حينئذ رب المال و لهؤلاء صفة المضارب الثاني . و قد انتقد البعض هذه الصورة لوقوع محاذير فقهية، كخلط الأموال المقدمة للمضاربة، و حساب الأرباح قبل تحقق التنضيف.

2. اعتبار البنك الإسلامي شريكا رب المال :و إيضاحه أن البنك من خلال مساهميه يعتبر شريكا للمودعين في موضوع المشاركة، و هي شركة عقد، ثم بعدئذ يصبح هذا المجموع رب المال وهم المساهمون و المودعون حين التعامل مع أصحاب المشاريع الاستثمارية هو المضارب.يو يقوم البنك بأعمال الإدارة في هذه الشركات مفوضا عن الجميع من مساهمين أو مودعين، و هذا الرأي يستتبع جواز الخلط و صحة المحاسبة قبل التنضيف ,على أنه لا مانع من بقاء هذين القيدتين في معاملات بين البنك وبين أصحاب المشاريع الاستثمارية الذين يعملون بمال الشركة مضاربة.

يمكن كذلك أن تتم المضاربة عن طريق إصدار سندات أو صكوك المضاربة لإنشاء مشاريع إستثمارية بين الممولين الذين يسهمون بحصص ممثلة في صكوك المضاربة و الصناديق الإستثمارية ,و بين إدارة تلك تلك المشاريع ,حيث تعتبر المضاربة البديل الشرعي لسندات القرض القائمة على الفائدة.

الإجارة: تعريفها، أركانها، حكمها و شروطها

تعريفها:

لغة: مشتقة من الأجر، وهو العِوض، ومنه سُمِّي الثواب أجرًا.
اصطلاحًا: عَرَّفَهَا الحنفية بقولهم: عقد على المنافع بعِوض.
وعَرَّفَهَا المالكية: تمليك منافع شيءٍ مباحة مدَّة معلومة بعِوض.
وعَرَّفَهَا الشافعية: عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل.
وعَرَّفَهَا الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدَّة معلومة، أو عمل معلوم بعِوض معلوم.
ونختار التعريف المختصر التالي: "تمليك المنافع بعِوض."

مشروعيتها:

اتفق الفقهاء على مشروعية الإجارة إلا مَنْ شذَّ مثل: أبي بكر الأَصم، والحسن البصري، وغيرهما؛ فإنهم لم يجيزوها [1]؛ لأن الإجارة بيع المنفعة، والمنافع حال انعقاد العقد معدومة القبض، وإنما تُستوفى شيئًا فشيئًا مع الزمن، والمعدوم لا يحتمل البيع، ولا يجوز إضافة البيع إلى شيء في المستقبل.
واستدلَّ الجمهور على جواز عقد الإجارة بالقرآن الكريم والسنة والإجماع.

• فمن القرآن ﴿: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6]، وقوله - تعالى - حاكمًا قول إحدى ابنتي شعيب - عليه السلام ﴿: -قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ * قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [القصص 26 ، : . 27]

وشرع مَنْ قبلنا شرع لنا -على الصحيح - ما لم يرد ناسخ.

• ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - : -أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه. [2].
وروى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجَّام أجره. [3].

وأجمع الصحابة على جواز الإجارة ومشروعيتها قبل وجود مَنْ منعها، ولحاجة الناس إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان المحسوسة، فلما جاز عقد البيع على الأعيان، وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع.

وعقد الإجارة من العقود المهمة في حياة الناس؛ لذا وجب الاهتمام به، وخاصة معرفة أحكامه وشروطه؛ لتكون أعمالنا وإجارتنا موافقة لشرع الله.

أنواعها:

الإجارة نوعان:

- 1- إجارة على المنافع: كاستئجار الدُّور، والأراضي، والدواب، والثياب.
- 2- إجارة على الأعمال: كاستئجار أرباب الحِرَف والصنائع، والحَدَم، والعَمَّال.

أركانها:

عند الجمهور أربعة:

- 1- عاقدان: مؤجِّر ومستأجر
- 2- صيغة الإيجاب والقبول.
- 3- الأجرة.
- 4- المنفعة.

شروطها:

ويشترط في عقد الإجارة أربعة أنواع من الشروط كما في عقد البيع [4].

شروط الانعقاد: فيشترط لانعقاد الإجارة:

1- أهلية العاقلين:

بأن يكون كل منهما عاقلًا مميزًا.

2- شروط النفاذ:

كون العاقد المؤجر مالِكًا لما يؤجره، أو وكيله، فلا تنقُذ إجارة الفضولي لعدم المِلْك أو الولاية، وإنما ينعقد موقوفًا على إجازة المالك.

3- شروط الصحة:

أ - رضا المتعاقدين: قال - تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ النساء. [29]:

ب - أن يكون المعقود عليه - المنفعة - معلوماً علماً يمنع المنازعة، والعلم بالمعقود عليه يكون ببيان محل المنفعة، وبيان المدة، وبيان العمل في إجارة الأعمال.

ج - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاً، فلا تجوز إجارة متعذر التسليم؛ مثل: عدم جواز إجارة البعير الشارد، والأخرس للكلام، والحائض لكنس المسجد.

د - أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعاً؛ مثل: دار للسكنى، وشبكة للصيد، فلا يجوز الاستئجار على المعاصي: كاستئجار إنسان للهو المحرم، أو تعليم السحر.

هـ - أن تكون الأجرة مالاً متقوماً معلوماً؛ قال - صلى الله عليه وسلم: -مَنْ استأجر أجيراً فليعلمه أجره [5]، والعلم بالأجرة لا يحصل إلا بالإشارة أو التعيين أو البيان.

و - خُلُو العقد من الشروط المفسدة؛ مثل: لو أجرة المالك داره على أن يسكنها هو شهراً، أو أجر سيارته على أن يركبها شهراً، فالإجارة فاسدة؛ لأن هذه الشروط لا يقتضيها العقد ولا يلائمها؛ لأن فيها منفعة زائدة لأحد المتعاقدين مشروطة في العقد، لا يقابلها عوض، فتكون رباً، وهو مفسد للعقد.

4- شروط لزوم الإجارة:

1- سلامة العين المؤجرة عن حدوث عيب يخل بالانتفاع بها، فلو حدث عيب بالسيارة المؤجرة أو انهدم البيت المؤجر انفسخ العقد.

2- ألا يحدث عذر بأحد العاقدين، كمن استأجر حملاً فمرض

حكم الإجارة:

حكم الإجارة الصحيحة: هو ثبوت المِلْك في المنفعة للمستأجر، وثبوت المِلْك في الأجرة المسماة للمؤجر؛ لأنها عقد معاوضة؛ إذ هي بيع المنفعة، وحكم الإجارة الفاسدة أنه إذا استوفى المستأجر المنفعة يجب أجر المثل.

صفة الإجارة:

جمهور العلماء على أن عقد الإجارة عقد لازم لا يفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها، أو ذهاب استيفاء المنفعة؛ لقوله - تعالى ﴿: -أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ المائدة[1] :، فلو أجره شيئاً ومنع المؤجّر المستأجر الشيء المؤجّر كلّ المدة أو بعضها، فلا شيء له من الأجرة؛ لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئاً.

انتهاء عقد الإجارة: فسخها.

- جمهور العلماء على أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين؛ لأنه عقد لازم كالبيع، وقال الحنفية: إن الإجارة تنتهي بموت أحد المتعاقدين.
- تنتهي الإجارة بالإقالة مثل البيع؛ لأنها معاوضة مال بمال.
- الإجارة تنتهي بهلاك العين المؤجرة المعيّنة؛ كالدار أو السيارة، وهلاك المؤجر عليه؛ كالثوب المؤجر للخياطة فتلف، أو دابة ماتت؛ لأن المنفعة زالت بالكلية.
- وإن كان التلف بعد مُضي مدة لها أجرة، انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط الواجب فيه.
- وتنفسخ أيضاً بانقلاع ضرر اكثري لقلعه، أو بُرئه؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه، وتنفسخ الإجارة لاستتجار طبيب ليداويه فبرأ.
- وإن غصبت العين المؤجرة حُرّ المستأجر بين الفسخ، وعليه أجرة ما مضى، وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل.

المراجع و المصادر:

[1] بدائع الصنائع 4/174، فتح القدير 5/105، الشرح الكبير 4/2، مغني المحتاج 2/332، المغني 5/398.

[2] رواه ابن ماجه.

[3] متفق عليه.

[4] ينظر في شروط الإجارة المراجع السابقة.

تعريف الشركة وأدلة مشروعيتها وأقسامها

تعريف الشركة في الفقه:

الشركة لغةً: بكسر الشين وسكون الراء (الشَّرْكََة)، وحُكِّي فتح الشين وسكون الراء وكسرهما (الشَّرْكََة - الشَّرْكََة)، وهي أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُهُمَا. وَيُقَالُ: شَارَكْتُ فُلَانًا فِي الشَّيْءِ، إِذَا صِرْتَ شَرِيكُهُ، وَأَشْرَكْتُ فُلَانًا، إِذَا جَعَلْتُهُ شَرِيكًا لَكَ. قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي قِصَّةِ مُوسَى: {وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي} [طه : 32].

الشركة اصطلاحاً: عرّفها الحنفية بقولهم: عقدٌ بين المتشاركين في الأصل والربح، وعرّفها الشافعية بقولهم: ثبوت الحق في شيءٍ لاثنتين فأكثر على جهة الشيوع، وعرّفها الحنابلة بقولهم: الاجتماع في استحقاقٍ أو تصرفٍ. وجميع هذه التعاريف تُعبر عن معنى الشركة في الاصطلاح الفقهي، وإن كان أكثرها دقةً هو تعريف الحنفية؛ لأنه يعبر عن حقيقة الشركة بأنها عقدٌ، أما التعاريف الأخرى فتُركّز على هدف الشركة وأثرها والنتيجة المترتبة عليها.

مشروعية الشركة:

ثبتت مشروعية الشركة بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع:

أما القرآن الكريم: قال تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ} [النساء : 12]، وقال في موضع آخر: {وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ} [ص : 24].

وأما السنة النبوية: عن سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ، عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكُ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلَنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ» ([5])، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا»

وأما الإجماع: أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها.

أنواع وأقسام الشركة:

تقسم الشركة إلى قسمين، هما: شركة الأملاك، وشركة العقود، ويتفرع عن هذين القسمين أقسام أخرى، سنقوم بالتحدث عنها في المطلبين التاليين.

أ- شركة الأملاك: وهي أن يملك شخصان فأكثر عيناً من غير عقد الشركة؛ كأن يمتلكانها عن طريق الإرث أو الهبة ([8])، وهي نوعان: نوعٌ يثبت بفعل الشريكين، ونوعٌ يثبت بغير فعلهما، على النحو الآتي:

ب- شركة اختيار: وهي التي تنشأ بفعل الشريكين؛ مثلاً: أن يشتريا شيئاً، أو يوهب لهما شيء أو يوصى لهما بشيء، فيقبلا، فيصير المشترى والموهوب والموصى به مشتركاً بينهما شركة ملك.

ج- شركة جبر: وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما؛ مثلاً: يرث اثنان شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك.

حكم شركة الأملاك: في شركة الأملاك بنوعيتها يعتبر كل واحدٍ من الشريكين أجنبياً في نصيب صاحبه، فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه؛ إذ لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر.

د- شركة العقود: وهي عقد بين المتشاركين في الأصل والربح معاً أو في الربح فقط، وهي تقسم إلى عدة أنواع:

النوع الأول: شركة العنان

وهي أن يشترك رجلان بماليتهما على أن يعملوا فيهما، والربح بينهما، وتُسمى بذلك؛ لأنهما يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا سَوَّيَا بين فرسيهما، وتساويا في السير، فإن عَنَانَيْهِمَا يكونان سواءً. وقيل: لأن كل واحدٍ منهما عَنٌّ له أن يشارك صاحبه. وقيل: هي مشتقة من الْمُعَانَنَةِ، وهي الْمُعَارَضَةُ، يقال: عَانَنْتُ فلاناً. إذا عارضته بمثل ماله وأفعاله. فكل واحدٍ من الشريكين معارضٌ لصاحبه بماله وفَعَالِهِ. وهذه الشركة جائزة بالإجماع، وهذا النوع من الشركات هو السائد بين الناس؛ لأن شركة العنان لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز أن يكون مال أحد الشريكين أكثر من الآخر، كما يجوز أن يكون أحدهما مسؤولاً عن الشركة والآخر غير مسؤول، ويجوز أن يتساويا في الربح أو يختلفا، فيوزع الربح بينهما حسب

الشرط الذي اتفقا عليه، أما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال فحسب؛ عملاً بقاعدة: «الربح على ما شرطاً، والوضيعة على قدر المالين»

النوع الثاني: شركة المضاربة

وهي عقد شَرَكَةٍ في الربح بمالٍ من جانب صاحب المال، وعملٍ من جانب الْمُضَارِبِ ، ويكون الربح بينهما على حسب ما اشترطا في العقد، أما الخسارة فتكون على صاحب المال فقط، ولا يخسر العامل إلا جهده وعمله فقط.

وهذه الشركة جائزة بالإجماع، ورويت عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم، ولم يُعَرَفْ لهم مخالفٌ، والحكمة تقتضيها؛ لأن الناس حاجةٌ إليها، فإن النقادين لا تُنَمَّى إلا بالتجارة، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، ولا كل من يحسنها له مالٌ، فَشُرِعَتْ لدفع الحاجة.

النوع الثالث: شركة الوجوه

وهي أن يشترك شخصان ليس لهما مالٌ، ولكن لهما وجاهةٌ عند الناس، فيقولان: اشتركنا على أن نشترى بالنسيئة، ونبيع بالنقد، على أن ما رزق الله سبحانه وتعالى من ربحٍ فهو بيننا على شرط كذا، وَتُسمَّى هذا النوع شركة الوجوه؛ لأنه لا يباع بالنسيئة إلا الوجيه من الناس عادةً.

وهذه الشركة جائزةٌ عند الحنفية، والحنابلة لأنها شركة عقد تتضمن توكيل كل شريكٍ صاحبه في البيع والشراء، وتوكيل كل واحدٍ منهما صاحبه بالشراء على أن يكون المشتري بينهما صحيحٌ، فكذلك الشركة التي تتضمن ذلك. هذا بالإضافة إلى أن الناس تعاملوا بها في سائر العصور من غير إنكارٍ من أحدٍ، وما اتفقا عليه يعد عملاً من الأعمال، فيجوز أن تنعقد عليه الشركة.

وذهب الشافعية والمالكية إلى بطلان شركة الوجوه؛ لأن الشركة إنما تتعلق على المال، أو على العمل، وكلاهما معدومان في هذه المسألة، مع ما في ذلك من الغرر؛ لأن كل واحدٍ منهما عاوض صاحبه بكسبٍ غير محدودٍ بصناعةٍ ولا عملٍ مخصوصٍ.

النوع الرابع: شركة الأبدان أو الأعمال:

وهي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم؛ كالاشتراك على عملٍ من الخياطة، أو غيره، فيقولوا: اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله عز وجل من أجرٍ فهي بيننا، على شرط كذا.

وهذه الشركة جائزة عند المالكية، والحنفية، والحنابلة، لأن المقصود منها تحصيل الربح، وهو ممكنٌ بالتوكيل، وقد تعامل الناس بها، ولأن الشركة تكون بالمال، أو بالعمل كما في المضاربة، وهنا عملٌ من الأعمال، أيضاً استدلووا بقول ابن مسعود رضي الله عنه: "اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ، وَسَعْدُ، فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ".

وقد اشترط المالكية لجوازها اتحاد الصنعتين والمكان؛ لأن اختلاف الصنعتين والمكان سيؤدي إلى الغرر.

وذهب الشافعية إلى بطلان هذا النوع من الشركة؛ لعدم المال فيها، ولما فيها من الغرر؛ إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا؛ ولأن كل واحدٍ منهما متميزٌ ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في الاحتطاب والاصطياد.

النوع الخامس: شركة المفاوضة:

وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عملٍ بشرط أن يكونا متساويين في رأس مالهما، وتصرفهما، ودينهما؛ أي (ملتئما)، ويكون كل واحدٍ منهما كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراءٍ وبيعٍ؛ أي أن كل شريكٍ ملزمٌ بما ألزم شريكه الآخر من حقوق ما يتجران فيه، وما يجب لكل واحدٍ منهما يجب للآخر؛ أي أنهما متضامنان في الحقوق والواجبات المتعلقة بما يتجران فيه، ويكون كل واحدٍ منهما فيما يجب لصاحبه بمنزلة الوكيل له، وفيما يجب عليه بمنزلة الكفيل عنه.

وقد أجاز الحنفية هذا النوع من الشركة؛ لأنها مشتملةٌ على أمرين جائزين، وهما: الوكالة والكفالة؛ لأن كل واحدةٍ منهما جائزة حال الانفراد، وكذا حالة الاجتماع، كالعنان؛ ولأنها طريق استئناء المال أو تحصيله، والحاجة إلى ذلك متحققة، فكانت جائزة كالعنان.

وأما الملكية، فأجازوا شركة المفاوضة بغير هذا المعنى الذي ذكره الحنفية: وهو أن تعقد الشركة على أن يكون كل شريك مطلق التصرف في رأس المال استقلالاً، دون حاجة إلى أخذ رأي شركائه، حاضرين أم غائبين، بيعاً وشراءً وأخذاً وعطاءً وكراءً واستكراءً، وضماناً وتوكيلاً وكفالةً وقراضاً وتبرعاً، وغيرها مما تحتاج إليه التجارة من تصرفٍ. ويُلزَم كل شريكٍ بكل ما يعملُه شريكه، ولا تكون إلا فيما تم العقد عليه من أموالهم، دون ما ينفرد به كل منهم من مالٍ لم يدخله في الشركة، وهي بهذا المعنى لا خلاف فيها بين الفقهاء. أما شركة المفاوضة حسب معناها عند الحنفية فهي غير جائزة عند الشافعية والحنابلة؛ لأنه عقدٌ لم يرد الشرع بمثله؛ لاشتمالها على أنواعٍ من الغرر؛ ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: "إن لم تكن شركة المفاوضة باطلةً فلا باطل أعرفه في الدنيا"؛ أشار بذلك إلى كثرة الغرر والجهالات فيها.

ختاماً : إن المجتمع البشري لن يحقق العدل والاستقرار والازدهار إلا من خلال الاهتمام بشريعة الإسلام، وتطبيق ما جاء فيها من مبادئ غايتها إسعاد البشر، وتنظيم شؤون حياتهم، وتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾. ومن خلال هذا الموضوع تحدثنا عن الشركة التي تعتبر جانباً من الجوانب الشرعية التي تنظم شؤون الناس، فبيّنا معنى الشركة، ودليل مشروعيتها، ثم تكلمنا عن قسميها الرئيسيين: شركة الأملاك وشركة العقود، وأوضحنا ما يتفرّع عن هذين القسمين من أنواعٍ أخرى، ذاكرين معنى كل نوعٍ، وحكمه الفقهي، مستنديين على ما جاء في مصادر الشريعة الإسلامية، وأمّهات كتب الفقه المعتمدة.

المراجع والمصادر الفقهية :

- [1] معجم مقاييس اللغة (265/3).
- [2] رد المحتار على الدر المختار (299/4).
- [3] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (221/3).
- [4] المغني لابن قدامة (3/5).

[5]) أخرجه البخاري في صحيحه (3/140/رقم 2497)، وأخرجه مسلم في صحيحه (3/1212/رقم 1589).

[6]) أخرجه الحاكم في المستدرک (2/60/رقم 2322) وصححه، ووافقه الذهبي.

[7]) المغني لابن قدامة (3/5).

[8]) كشف القناع عن متن الإقناع (3/496).

[9]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/56).

[10]) المرجع السابق.

[11]) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/312).

[12]) رد المختار على الدر المختار (4/299).

[13]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/57)، المغني لابن قدامة (5/12).

[14]) الإجماع لابن المنذر (100/رقم 512).

[15]) الفقه الإسلامي وأدلته (5/3881).

[16]) رد المختار على الدر المختار (5/645).

[17]) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/53)، المغني لابن قدامة (5/18).

[18]) الإجماع لابن المنذر (100/رقم 513).

[19]) كشف القناع عن متن الإقناع (3/507).

[20]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/57).

بيع السلم: تعريفه، شروطه و أركانه.

تعريف بيع السلم:

عقد السِّلْم هو نوعٌ من أنواع البُيوع، ويعني: أن يقومَ المشتري بتسليم الثمنِ للبائع في مجلس العقد قبل تسليمه السلعة المراد شراؤها، على أن يقومَ البائع بتسليم السلعة المتفق عليها في وقتٍ وأجلٍ معلوم. ١

مشروعية بيع السلم:

السِّلْم حكمه جائزٌ، وثبتت مشروعيّته في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، ودليل مشروعيّته كما يأتي :

القرآن الكريم :

قال الله -تعالى :- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، ٣ بين عبد الله بن عباس -رضي الله عنه - أنّ مراد الله -تعالى - من الآية الكريمة هو عقد السِّلْم، حيث قال " :أشهدُ أنّ السِّلْفَ المضمونَ إلى أجل مُّسَمًّى قد أحلّه الله في كتابه، وأذنَ فيه، ثم قرأ هذه الآية"، والمقصود بالسِّلْف هو عقد السِّلْم. ٤

السنة النبوية:

ورد عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال :قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -المدينة، وهم يُسَلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ :مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، دَلَّ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ صِرَاحَةً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ السِّلْمِ مَعَ مُرَاعَاةِ الشَّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ، وَهِيَ كَوْنُ الْأَجَلِ وَالْوِزْنِ وَالْكَيْلِ مَعْلُومًا. ٦

الإجماع:

إذ أجمع الفقهاء كلّهم على جواز بيع السِّلْم. ٧

الحكمة من تشريع بيع السلم:

تتجلّى حكمة مشروعيّة بيع السلم؛ لحاجة الناس إليه، وتحقيق مصالحهم، ومراعاة أحوالهم، والتوسعة عليهم في معاملاتهم، فالبائع يحتاج إلى رأس المال لإتمام إنتاج سلعته، والإنفاق على نفسه وأهله إلى أن يحين موعد الإنتاج، والمشتري يحتاج إلى السلعة بسعرٍ أقلّ من سعر بيع السلعة الحالي، وبذلك ينتفع البائع من رأس المال، وينتفع المشتري بنقصان ثمن السلعة عن

مَثِيلَاتُهَا.

شروط بيع السلم:

- يُشْتَرَطُ لعقد السِّلْمِ ما يُشْتَرَطُ في سائر عقود البيع، إِلَّا أَنَّ هناك شروطًا خاصَّةً به تُمَيِّزُهُ عن باقي أنواع البيوع، وفيما يأتي بيانها: ٨
- أَنَّ يكونَ المسلمُ فيه وهو المبيع، موصوفًا وصفًا تامًّا ودقيقًا؛
 - بأن يذكَّرَ نوعه وجنسه ولونه وجودته؛ لِئَلَّا يُؤَدِّي إلى المنازعة بينهما .
 - أَنَّ يكونَ المسلمُ فيه مُؤَجَّلًا أَجَلًا مَعْلُومًا
 - . أَنَّ يكونَ المسلمُ فيه دينًا، أي موصوفًا في الذمَّة .
 - أَنَّ يكونَ المسلمُ فيه مَقْدُورًا على تسليمه عند حُلُولِ الأجل،
 - بأن يكون جنس المسلم فيه موجوداً في الأسواق بنوعه وصفته، من وقت العقد إلى وقت حُلُولِ أَجَلِ التَّسْلِيمِ .
 - أَنَّ يكونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا . أَنَّ يتمَّ تسليم الثَّمَنِ في مجلس العقد . أَنَّ تكون الصِّيْغَةُ بلفظ السِّلْمِ أو السَّلَفِ .

أركان السلم:

- يَعَدُّ بيع السِّلْمِ عقداً كسائر العقود، لا بدَّ لانهقاده من توافر أركانه، وفيما يأتي بيانها: ٢
- الصِّيْغَةُ: هي الإيجاب ويصدر من المشتري، والقَبُولُ يصدر من البائع، وتجرّد الإشارةُ هنا إلى أَنَّ الحنفِيَّةَ يروْنَ أَنَّ ركنَ السِّلْمِ هو الإيجاب والقَبُولُ فقط، بخلاف الجُمهور الذين قالوا أَنَّ أركانَ السِّلْمِ ثلاثة: الصِّيْغَةُ، والعاقدان، والمعقود عليه
- .العاقدان وهما المشتري ويُسمَّى المسلم، والبائع يُسمَّى المسلم إليه .
- المعقود عليه وهو رأس مال السِّلْمِ وهو الثَّمَنُ، والمسلم فيه وهو المبيع أو السلعة.

المراجع و المصادر:

1. دبيان الديان (1432)، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (الطبعة
2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 194، جزء 25. بتصرف.
3. سورة البقرة، آية 282:
4. ابن نور الدين (2012)، تيسير البيان لأحكام القرآن، سوريا: دار النوادر، صفحة 161، جزء 2
5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم 1604:، حديث صحيح.
6. ابن فُهيّرة (1417)، الإفصاح عن معاني الصحاح، صفحة 102، جزء 3. بتصرف
7. عبد الرحمن المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، لبنان: دار الكتاب العربي ، صفحة 312، جزء 4. بتصرف.
8. عبد الله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة 2)، الرياض: مدار الوطن، صفحة 82، جزء 6. بتصرف.

الهبة: تعريفها و أحكامها

تعريف الهبة:

الهبة: العطية. يُقال، وهبه مالاً: أي أعطاه مالاً. (لسان العرب لابن منظور ج6 ص4929)
معنى الهبة: تمليك في الحياة بغير عوض (بغير مقابل)، وتسمى أيضاً: الهدية والعطية (المغني لابن قدامة ج8 ص239)

مشروعية الهبة:

الهبة مشروعة، و مندوب إليها لقوله تعالى: (فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) (النساء:4).

وقوله سبحانه: (وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (البقرة:177)

روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْعَائِدُ فِي هَبِّهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)) (البخاري حديث 2589/ مسلم حديث 1622)

ومن السنة: المكافأة على الهبة حينما يتيسر ذلك للموهوب له،
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. (البخاري حديث 2585)

فائدة: يُثِيبُ عَلَيْهَا: أَي يُعْطِي الَّذِي يُهْدِي لَهُ بَدَلَهَا. (فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج 5 ص249)
وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (المائدة:2)
وهي للأقارب أفضل؛ لأن فيها صلة الرحم. (الفقه الإسلامي للزحيلي ج5 ص6:6 ص7) (المبسوط للسرخسي ج12 ص47)

أركان الهبة:

للحبة أربعة أركان هي:

- 1- الواهب، 2- الموهوب له، 3- الموهوب، 4- صيغة الهبة هي الإيجاب والقبول.
- (الفقه الإسلامي للزحيلي ج5 ص7)

شروط الهبة:

هناك شروط تتعلق بالواهب, والموهوب له, والشئ الموهوب.

أولاً: الواهب:

يشترط في الواهب الشروط الآتية:

1- أن يكون بالغاً , عاقلاً , رشيداً.

2- أن يكون مالكاً للشئ الموهوب.

3- أن يكون راضياً ومختاراً.

(الفقه الإسلامي للزحيلي ج5 ص12)

(بدائع الصنائع للكاساني ج6 ص118)

ثانياً: الموهوب له:

يُشترط في الموهوب له:

1- أن يكون الموهوب له موجوداً في الحقيقة وقت الهبة.

2- أن يكون الموهوب له أهلاً لملك ما يوهب له.

(الموسوعة الفقهية الكويتية ج42 ص125)

ثالثاً: الموهوب:

يشترط في الشئ الموهوب ما يلي:

1- أن يكون موجوداً قبل الهبة, لأنه تملك في الحال.

2- أن يكون مالاً متقوماً, فلا تنعقد هبة ما ليس بمال, كالهيئة, والدم, والخمر, وما شابه ذلك.

3- أن يكون معلوماً ومملوكاً للواهب.

(الفقه الإسلامي للزحيلي ج5 ص12 : ص15)

ألفاظ الهبة:

الهبة تكون بلفظ يدل على التملك مثل: وهبتك, أو أهديت لك, أو أعطيتك, أو هذا لك, ونحو ذلك من

الألفاظ التي تدل على هذا المعنى.

(المغني لابن قدامة ج8 ص345)

هبة الوالد لأبنائه:

يَجِبُ عَلَى الْوَالِدِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فِي الْعَطِيَّةِ، وَإِذَا لَمْ يَخْتَصَّ أَحَدُهُمْ بِمَعْنَى التَّفْضِيلِ، فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِعَطِيَّتِهِ، أَوْ فَاضَلَ بَيْنَهُمْ فِيهَا أَثَمَ، وَوَجِبَتْ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ؛ إِمَّا رَدُّ مَا فَضَّلَ بِهِ الْبَعْضَ، وَإِمَّا إِتْمَامُ نَصِيبِ الْآخَرِ. (المغني لابن قدامة ج8 ص256)

لجنة الفتوى بالأزهر:

أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر جواباً عن سؤال حول إمكان التمييز بين الورثة، وتضمنت الفتوى ما يلي:
أولاً: يجب على الوالدين التسوية بين الأولاد في العطية والهدايا والإنفاق، ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا لمبرر يأتي، عملاً بالأحاديث السابقة الأمرة بالتسوية.
ثانياً: إذا أنفق أحد الوالدين على أحد الأولاد نفقة ذات قيمة بأن زوجه ودفع له مهر الزوجة، أو أنفق على تعليمه بما أوصله إلى وظيفة ذات غناء، أو جهز إحدى بناته، كان عليه أن يعوض سائر ولده الآخرين بمقدار ما أنفقه على ولده الأول.

ثالثاً: يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض لمبرر شرعي، ومن المبررات الشرعية: العاهات المانعة من التكسب كالزمانة (المرض الشديد والطويل الأجل)، والعمى المانع، والشلل، وكذلك العجز عن التكسب، والاشتغال بالعلم الديني. (مجلة الأزهر. العدد الثالث من السنة الرابعة عشرة).

هبة المجهول:

لا تصح هبة الشيء المجهول، مثل الحمل في البطن، واللبن في الضرع، وما شابه ذلك، لأن هذا مجهول معجز عن تسليمه. (المغني لابن قدامة ج8 ص249)

تعليق الهبة على شرط:

لَا يَصِحُّ تَعْلِيْقُ الْهَبَةِ بِشَرْطٍ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِكُ لِمُعَيَّنٍ فِي الْحَيَاةِ، فَلَمْ يَجْزْ تَعْلِيْقُهَا عَلَى شَرْطٍ، كَالْبَيْعِ. فَإِنْ عَلَّقَهَا عَلَى شَرْطٍ، كَانَ وَعْدًا.

وَأِنْ شَرَطَ فِي الْهَبَةِ شَرْطًا ثَنَائِيًّا مُقْتَضَاها، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: وَهَبْتُكَ هَذَا، بِشَرْطِ أَنْ لَا تَهَبَهُ، أَوْ لَا تَبِيعَهُ، أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَهَبَهُ أَوْ تَبِيعَهُ، أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَهَبَ فُلَانًا شَيْئًا، لَمْ تَصِحَّ الشُّرُوطُ. (المغني لابن قدامة ج8 ص250)

هبة المريض عند الموت:

لا تصح هبة الشخص المريض مرض الموت: وهو الذي يعجز المريض فيه عن ممارسة العمل وينتهي به إلى الموت. (فقه السنة للسيد سابق ج4 ص295)

الرجوع في الهبة:

لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما أعطاه لولده. (المغني لابن قدامة ج8 ص277)
روى أبو داود عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ))-(حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 3023)

قبض الطفل للهبة:

الطِّفْلُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ، وَلَا قَبُولُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ، وَوَلِيُّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ أَمِينٌ، فَهُوَ وَلِيُّهُ؛ لِأَنَّهُ أَشْفَقَ عَلَيْهِ، وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ أَبُوهُ الْأَمِينُ، وَلَهُ وَصِيٌّ، فَوَلِيُّهُ وَصِيُّهُ؛ لِأَنَّ الْأَبَ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ، فَجَرَى مَجْرَى وَكَيْلِهِ. وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَيْرَ مَأْمُونٍ، لِفَسْقٍ أَوْ جُنُونٍ، أَوْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيٍّ، فَأَمِينُهُ الْحَاكِمُ. (المغني لابن قدامة ج2 ص25)
بطلان الهبة:

تبطل الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض.(المغني لابن قدامة ج8 ص243)
ختاماً: أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن يجعلَ هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله دُخْرًا لي عنده يوم القيامة (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام.

الرهن: تعريفه و شروطه و أركانه

الرهن في اللغة: يُطلق الرهن في اللغة بمعنى الثبوت والدوام، كما يُطلق على الحبس؛ فمن الأول قولهم: نعمة راهنة؛ أي ثابتة ودائمة، ومن الثاني قوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ المدثر [38]؛ أي: محبوسة بكسبها وعملها؛ بحيث يُمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من تلك العين.

وأما معناه الشرعي: فقد عرّفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين، فإذا استدان شخص دينًا من شخص آخر وجعل نظر ذلك الدين عقارًا أو حيوانًا محبوسًا تحت يده حتى يقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعًا [1].

المقصود منه: إن المقصود من الرهن هو بيع العين المرهون عند الاستحقاق، واستيفاء الحق منها، فكل ما جاز بيعه جاز رهنه، ومقتضاه أنه لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه [2].

فائدة:

إذا أقرض ذمي ذميًا خمرًا ثم أسلما أو أسلم أحدهما، بطل القرض ولم يجب على المقرض شيء، سواء كان هو المقرض أم المقرض؛ لأنه إذا أسلم لم يجز أن يجب عليه خمر لعدم ماليتها، ولا يجب بدلها؛ لأنه لا قيمة لها، ولذلك لا يضمنها إذا أتلّفها، وإن كان المقرض [3].

ثانيًا: مشروعية الرهن:

الرهن مشروع في الكتاب والسنة والإجماع:

الدليل على مشروعية الرهن من الكتاب: قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ البقرة. [283]:

و أما الدليل على مشروعية الرهن في السنة النبوية؛ فقد قال الإمام البخاري: "حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس - رضي الله عنه - قال: ولقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعه بشعير ومشيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بجذب شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول: ((ما أصبح لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا صاع، ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات)) [4].

حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعامًا ورهنه درعه [5].

الإجماع:

أجمع العلماء على مشروعية الرهن ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد، وإن كانوا قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر.

ثالثاً: مشروعيته في الحضر:

اختلف العلماء في مشروعية الرهن في الحضر؛ فقال الجمهور: يُشرع في الحضر، كما يشرع في السفر؛ لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - له وهو مُقيم بالمدينة، وأما تقيده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب؛ فإن الرهن غالباً يكون في السفر.

فائدة:

قال ابن حجر - رحمه الله -: في قول البخاري في التبويب للحديث في الحضر "فيه إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب، فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر، وهو قول الجمهور، واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقاً على الدين؛ لقوله تعالى ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: 283]، فإنه يُشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق، وإنما قيده بالسفر؛ لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب.

شروط الرهن:

أولاً: شروط الصيغة.

يُشترط في الصيغة شروط خمسة:

- 1- الشرط الأول: موافقة القبول للإيجاب.
- 2- الشرط الثاني: اتصال القبول بالإيجاب.
- 3- الشرط الثالث: عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر.
- 4- الشرط الرابع: وضوح دلالة الإيجاب والقبول، وعلم كل عاقد بما صدر من الآخر وفهمه له.
- 5- الشرط الخامس: ألا يكون في الصيغة تعليق لعقد الرهن أو إضافة له إلى وقت.

ثانياً: شروط المرهون:

يشترط في المرهون خمسة شروط:

- 1- الشرط الأول: أن يُمكن بيعه عند حلول الأجل.
- 2- الشرط الثاني: أن يكون المرهون عيناً، لا ديناً ولا منفعة.

- 3- الشرط الثالث: أن يكون المرهون مقبوضاً للمرتهن.
4- الشرط الرابع: صلاحية المرهون للثبوت يد المرتهن عليه.
5- الشرط الخامس: أن يكون المرهون منفصلاً متميزاً عما ليس بمرهون.

ثالثاً: شروط المرهون به:

وهي خمسة شروط:

- الشرط الأول: أن يكون المرهون به ديناً.
الشرط الثاني: أن يكون الحق ثابتاً؛ أي: موجوداً حال الرهن لا موعوداً به.
الشرط الثالث: أن يكون الدين لازماً أو آيلاً إلى اللزوم.
الشرط الرابع: أن يكون المرهون به مما يُمكن استيفاءه من الرهن.
الشرط الخامس: أن يكون المرهون به معلوم القدر [6].

أركان الرهن:

للهان أركان خمسة هي: الراهن، والمرهون، والمرتهن، والشيء الذي فيه الرهن، وصفة عقد الرهن.
الركن الأول: فأما الراهن، فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد، والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سداداً، ودعت إليه الضرورة عند مالك.
وأنفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنه، وقال أبو حنيفة: يجوز، واختلف قول مالك في الذي أحاط المدين بماله، هل يجوز رهنه؟ أعني: هل يلزم أم لا يلزم؟ فالمشهور عنه أنه يجوز؛ أعني قبل أن يُفلس.
الركن الثاني: وهو الرهن، قالت الشافعية:

يصح بثلاثة شروط:

- الأول: أن يكون عيناً؛ فإنه لا يجوز أن يرهن الدين.
الثاني: أن لا يتمتع إثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف؛ ومالك يُجيز رهن المصحف، ولا يقرأ فيه المرتهن، والخلاف مبني على البيع.
الثالث: أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل، ويجوز عند مالك أن يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يبدُ صلاحه، ولا يُباع عنده في أداء الدين إلا إذا بدا صلاحه، وإن حلَّ أجل الدين، وعند الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه، ويُباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع.
الركن الثالث: وهو الشيء المرهون فيه.

الوقف: تعريفه و أحكامه

الوقف لغة:

الحبس عن التصرف ويقال : وقفت كذا أي حبسته أو تصدقت به أو أبدته أي جعلته في سبيل الله إلى الأبد ، وجمعه أوقاف.

وشرعا:

تحبىس الأصل، وتسبيل المنفعة على بر أو قرابة بحيث يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.

نشأته:

أول وقف في الإسلام هو وقف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وذكر ابن خزيمة في صحيحه :باب ذكر أول صدقة محبسه تصدق بها في الإسلام، ثم ذكر اثر ابن عمر معلقا.

الأصل في مشروعيته:

شرع الله الوقف وندب إليه وجعله قرابة من القرب التي يتقرب بها إليه وأصل مشروعيته من الكتاب والسنة الثابتة والإجماع أما الكتاب فعموم الآيات التي تحث على الإنفاق والصدقة كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.

أما السنة:

فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : "أصاب عمر بخير أرضاً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال :أصببت أرضاً لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال :إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وإنما هي صدقة في الفقراء والقريب والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه . "وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال :قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم" - إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث :صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له . "أخرجه مسلم

أما الإجماع:

يقول الترمذي معلقاً على حديث ابن عمر السابق في وقف عمر للأرض التي أصابها بخير ..والعمل على

هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك. وقد حكى الكاساني في البدائع: الإجماع على جواز وقف المساجد. وقال القرطبي: لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلفوا في غير ذلك. فقد حكى الشوكاني في نيل الأوطار أن الترمذي قال: لا نعلم خلافاً بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلفوا في غير ذلك. وعن انس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره، من علم علماً، أو كرى نهرًا أو حفر بئرًا، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجدًا، أو ورث مصحفًا أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته - رواه ابن ماجه - ولقد جمع السيوطي رحمه الله ما ورد في الأحاديث النبوية من أنواع الصدقات الجارية ونظمها في:

عمل الصحابة:

قال جابر رضي الله عنه: ما أعلم أحدًا كان له مال من المهاجرين والأنصار، إلا حبس مالا من ماله صدقة مؤبدة لا تشتري أبدًا، ولا توهب، ولا تورث. وقال الحميدي شيخ البخاري: تصدق أبو بكر بداره على ولده، وعمر بربعة عند المروة، وعثمان برومة، بئر بالمدينة، وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة، و داره بمصر، وأمواله بالمدينة على ولده، وتصدق سعد بداره بالمدينة، و داره بمصر على ولده، وعمرو بن العاص بالوهط، وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده. قال: فذلك كله إلى اليوم، فإن الذي قدر منهم على الوقف، وقف، واشتهر ذلك فلم ينكره أحد، فكان إجماعاً.

حكم الوقف:

يعدّ الوقف من الأعمال المستحبة التي يمتد أثرها ونفعها إلى ما بعد الممات، وهو من أعظم الصدقات التي يتقرب به العبد إلى الله، ومن أفضل أعمال البر والإحسان؛ لعموم فائدتها على الآخرين، فقد روى أبو هريرة عن رسول الله قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

وتعددت الأقوال في حكمه عند المذاهب على النحو الآتي:

مباح: وهو قول الحنفية

مستحب: وهو قول عامة أهل العلم. والقول بالإباحة يختلف عن الاستحباب، فيكون مباحاً إن لم تكن نية صاحبه وقصده البر والتقرب من الله، أما إن كانت النية والقصد منه القيام بعمل خير يتقرب به صاحبه من الله فهو مستحب.

غير مشروع :وهو مذهب أهل الكوفة، وشريح، وقول نُسب إلى أبي حنيفة.
لا يصحّ إلا في الكراع والسلاح :وهو قول علي بن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنهما، والكراع :
اسم يجمع الخيل والسلاح.

شروط الوقف:

- يُشترط لصحة الوقف مجموعة شروط، وهي:
- ✓ تحديد العين الموقوفة، وأن تكون منفعتها مستدامة مع بقاء عينها
- ✓ أن تكون هذه العين فيها برّ؛ كالمساجد، وكعمل وقف للفقراء .
- ✓ أن يكون الوقف على جهة معيّنة ومعلومة، وذلك بتسميتها
- ✓ أن يكون دائماً غير محدد بمدة معيّنة، أو معلقاً على حدث معيّن، ويُستثنى من ذلك ما وقفه صاحبه حتى موته .
- ✓ أن يكون الواقف ممن يصح تصرّفه فيما وقفه .

ويصح الوقف بالقول والفعل، أما القول كقول الواقف :حبست أو وقفت أو سبّلت وغير ذلك من المعاني التي تفيد معنى الوقف، أما الفعل كأن يبني مسجداً ويدعو الناس للصلاة فيه، أو أن يبني مشفى ويدعو الناس لعلاج مرضاهم فيه

أنواع الوقف:

للوقف أنواع متعددة تنقسم بحسب اعتبارات كثيرة، وينقسم الوقف باعتبار غرضه إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتي:

الوقف الذريّ أو الأهلي: هو ما يكون الواقف قد وقفه على ذريته من الأسرة، فإن لم يتبقّ من الأسرة أحد صار وقفاً خيراً

الوقف الخاص أو الخيري : هو ما يكون في أصله على جهة خيرية في أوجه البر والخير وتقديم المنفعة للغير .
الوقف العام :هو ما يكون منذ بدايته قائم على تقديم المنفعة العامة؛ ومنها المساجد والمشافي، والأراضي الخراجية التي لم توزّع على الفاتحين، وإنّما جعلت ليستفيد منها الأجيال القادمة .ويُقسم الوقف باعتبار المحلّ الموقوف إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتي:

وقف العقار : وقد اتفق العلماء القائلون بمشروعية الوقف على جواز وقف العقار، وأنه مما يتقرب به العبد من الله، حيث نقل هذا الاتفاق القرطبي، وابن قدامة المقدسي، والنووي، وغيرهم عن الصحابة

الوقف المنقول : وينقسم إلى منقول لا يمكن الانتفاع به إلا بتلف عينه؛ كالطعام، فقد نُقل عن الجمهور أنه وقف غير جائز، وإلى منقول يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه؛ كالسلاح والحيوان والأجهزة وغيرها

وقف الدراهم والدنانير : ورجع العديد من أهل العلم أنه وقف جائز حتى لو لم تبقى عينها إن كانت قد ذهبت لغاية شرعية.

أفضل أنواع الوقف:

لا يقتصر الوقف على وقف شيء معين، ولا تكون الأفضلية فيه لوقف شيء دون آخر، والأفضلية فيه تقوم على ما يكون فيه منفعة لعامة المسلمين في كل مكان وزمان، مثل الوقف على المساجد، وطلبة العلم، والمجاهدين في سبيل الله، والأقارب، والفقراء من المسلمين.

وإن كانت القرية بلا مدرسة فأفضل الوقف بناء المدارس، وإن كان الوقت قد نودي للجهاد فيه فأفضل الوقف السلاح وأدوات الحرب، وإن كانت المدينة لا يوجد بها مكان لعلاج المرضى فأفضل الوقف بناء المستشفيات، فتكون الأفضلية مرتبطة بحاجة الناس لذلك الوقف

الكفالة- تعريفها وحكمها

معنى الكفالة:

الكفالة هي إحدى المعاملات المالية التي يتعامل بها الناس، وأما عن تعريفها فقد اختلف الفقهاء في ذلك، بناءً على ما يترتب على الكفالة من آثار، وهنا سندكر تعريفاً يتضمّن ما اشتركت كافة التعريفات على اشتماله من قدر مشترك من الضمان.

فتعريف الكفالة هو الالتزام الذي يترتب عليه إضافة ما في ذمة الأصيل إلى ذمة الكفيل، فيما يترتب عليه من ديون، وعلى الكفيل أن يتحمل ما يُطالب به الأصيل من دين أو عين، والكفيل هو الضمين ويُطلق عليه الحميل أو القبيل، ومن هنا نخرج بأن الكفيل هو الضامن، استدلالاً بالحديث الشريف: “لا تحلّ المسألة إلا لثلاثة، ومنهم رجل تحمل حمالة بين قوم والمقصود هنا رجل تحمّل مسؤولية دين أو غرامة عن غيره من الناس.

وأطلق بعض الفقهاء على الكفيل لفظ الزعيم، من قوله تعالى في سورة يوسف الآية: “72 قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ”، ولفظ الزعيم هنا جاءت بمعنى الكفيل، واستعمل البعض الآخر اسم القبالة للتعبير عن الكفالة، لأن القبالة تشمل الكفالة في المال، والعين، والكفالة في النفس، فهي أعم من لفظ الكفالة.

حكم الكفالة:

شُرعت الكفالة في القرآن الكريم والسنة والإجماع، فذكرت في القرآن الكريم في سورة يوسف، في الآية المذكورة أعلاه، أما في السنة النبوية الشريفة، فقد وردت الكثير من الأحاديث التي دلّت على مشروعية الكفالة، نذكر منها قول النبي - عليه الصلاة والسلام: “العارية مؤدّاة والمنحة مردودة والدّين مقضيّ والزعيم غارم.”

أما في الإجماع فقد أجمع الكثير من الفقهاء على جواز عقد الكفالة، بسبب حاجة الناس إليها، ورفع الضيق والخرج عن المدين، مستدلين بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، كما أنّ النبي عليه الصلاة والسلام، بُعث والناس يتعاملون بالكفالة فأقرّهم ولم ينه عن ذلك.

مشروعيتها ودليلها:

الكفالة مشروعة في الإسلام، ولقد استدل العلماء على مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.

أ-أما الدليل من القرآن الكريم :فقلوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:"ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم" قال ابن عباس :الزعيم الكفيل.

ب-وأما الدليل من السنة فأحاديث منها:

1-عن سلمة بن الأكوع قال : "كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجنابة فقالوا :صل عليها فقال :هل عليه دين؟ قالوا :لا، قال :فهل ترك شيئاً؟ قالوا :لا، فصلى عليه .ثم أتى بجنابة أخرى، فقالوا :يا رسول الله صل عليها، قال :هل عليه دين؟ قيل :نعم، قال :فهل ترك شيئاً؟ قالوا :ثلاثة دنائير، فصلى عليها، ثم أتى بالثالثة فقالوا :صل عليها، قال :هل ترك شيئاً؟ قالوا :لا، قال :فهل عليه دين؟ قالوا : ثلاثة دنائير، قال :صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة :صلّ عليه يا رسول الله وعليّ دينه، فصلى عليه " رواه البخاري.

والحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

2-وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "الزعيم غارم"، رواه أبو داود والترمذي قال الترمذي :حديث الحسن.

3-وروي أنه صلى الله عليه وسلم "تحمل عن رجل عشرة دنائير" رواه الحاكم.

ج-وأما الدليل من الإجماع :أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع.

الوكالة: تعريفها وحكمها، الكفالة: تعريفها وحكمها

الوكالة: تعريفها وحكمها:

الوكالة لغة: بفتح الواو وكسرهما -: تطلق على الحفظ؛ كما في قوله -تعالى- ﴿: -حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ آل عمران [173 ؛ أي: الحافظ. وتطلق على التفويض، ومنه قوله -تعالى- ﴿: -وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ الأحزاب [3 ؛ أي: فَوَضَّ أَمْرَكَ إِلَى اللَّهِ.

وشرعاً: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة؛ أي: أن يفوض المرء غيره بالقيام بتصرف يملك هذا المفوض القيام به بنفسه، ليقوم به عنه.

شروعيتها:

الوكالة مشروعة وجائزة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما في الكتاب، فقوله -تعالى- ﴿: -وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ النساء [35] ، فإذا حصل النزاع بين الزوجين واشتدَّ، يُعَيَّنُ حَكَمَانِ يكونان وكيلين عنهما، ينظران في الأمر.

وقوله -تعالى- -حكاية عن يوسف -عليه السلام ﴿: -اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ يوسف [55 ؛ أي: وكيلًا.

وأما السنة، فأحاديث كثيرة: منها ما جاء في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم - بعث السعاة لأخذ الزكاة، ومنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان -رضي الله عنهما.

• وأجمع علماء الأمة على جواز الوكالة؛ وذلك لأن الحاجة داعية إليها،

لأن من الناس من لم يؤت القدرة والكفاءة وما يؤهله للقيام بأعمال قد يكون في أمس الحاجة إليها.

حكمتها:

كما سبق، فإن من الناس من قد يكون صاحب حق، ولكنه لم يؤت من الحجة واللسان والفصاحة والبيان ما يجعله قادرًا على أن يظهر حقه ويدافع عن نفسه، فكانت المصلحة في تشريع الوكالة سدًا للحاجة وتيسيرًا للمعاملة ورفعًا للحرَج الذي جاء

شرع الله - تعالى - برفعه؛ إذ قال - تعالى ﴿: - وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78] :

حكمها:

- قلنا: إن الوكالة جائزة ومشروعة، والأصل فيها الإباحة.
- وقد تكون مندوبة: إن كانت إعانة على مندوب.
- وقد تكون مكروهة: إن كان فيها إعانة على مكروه.
- وقد تكون حرامًا: إن كان فيها إعانة على أمر محرّم.
- وقد تكون واجبة: إن ترتّب عليها دفع ضرر عن الموكل، كما إذا وكله بشراء طعام مضطر إليه وهو عاجز عن شرائه.

أركانها:

للكالة أركان أربعة، ولكل ركنٍ شروطٌ تختصها فيما يلي:

1- الموكّل:

وهو الذي يستعين بغيره، ويشترط فيه أن يكون له شرعًا حق التصرف فيما أذن لغيره أن يقوم به، فلا يصح توكيل الصبي، أو المجنون، أو المغمى عليه مطلقًا؛ لأنهم لا تصح وكالتهم شرعًا، ولا يصح توكيل المحجور عليه لسفه في التصرف المالي؛ لأنه لا يملك مباشرته.

2- الوكيل:

وهو الذي يقوم بالتصرفات نيابة عن غيره بإذن منه وتوكيل، ويشترط فيه أن يكون: عاقلًا، بالغًا، راشدًا، أو بعبارة أخرى أن تصح مباشرته للتصرف المأذون فيه لنفسه، ويشترط أن يكون الوكيل مُعَيَّنًا فلو قال لاثنتين: وكّلت أحكما ببيع داري لم يصحّ، وكذلك لو قال: وكلت ببيع داري كل من أراد بيعها.

3- الصيغة:

وهي الإيجاب والقبول، ويشترط فيها شرطان:

أ - أن يكون من الموكل لفظ يدلّ على رضاه بالتوكيل صراحة أو كناية؛ كقوله: وكّلتك ببيع داري هذا، صراحة أو كناية؛ كقوله: أقمّتك مقامي في بيعه، ويكفي من الوكيل ما يدل على القبول ولا يشترط فيه اللفظ.

ب - عدم تعليقها بشرط على الأصح؛ كأن يقول :إن جاء زيد من سفره فأنت وكيلتي، أو إذا جاء شهر رمضان فقد وكلتك بكذا.

4- الموكل فيه :وهو التصرف الذي يقوم به الوكيل نيابة عن الموكل، ويشترط فيه شروط؛ هي:

أ -أن يكون الموكل به مملوكًا للموكل، فلا يصح أن يوكل فيما لا يملكه.

ب -أن يكون الموكل به معلومًا ولو من بعض الوجوه، فلا يصح أن يقول :وكلتك في بعض أموالتي.

ج -أن يكون الموكل به قابلاً للنيابة، فلا يصح التوكيل في العبادات الدينية المحضة؛ كالصلاة والصوم،)وسياقي الكلام مفصلاً فيما يصح التوكيل فيه.

د -ألا يكون الموكل فيه من الأمور المباحة، فلا يصح أن يوكله بالاحتطاب أو الاحتشاش عند البعض، فإذا حصل في شيء مما ذكر فهو للوكيل وليس للموكل فيه شيء.

فيما يصح التوكيل فيه وما لا يصح:

•الوكالة في حقوق الله -تعالى:

قال جمهور العلماء بجواز التوكيل في الحدود إثباتاً واستيفاءً، فيجوز التوكيل في إقامة دعوى في حد السرقة وحد القذف والزنا؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وَكُلُّ أُنثَى فِي إِبْثَاتِ وَاسْتِيفَاءِ حَدِّ الزَّانَا؛ حيث قال :واغدُ يا أنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، وفرّق أبو حنيفة ومحمد بين الإثبات والاستيفاء.

•الوكالة في حقوق العباد:

وهي كل ما يتعلق بأفرادهم على أنهم أفراد لا جماعة؛ كالبيع، والشراء، والزواج، والطلاق، والشركة، ونحو ذلك، فمثل هذه الحقوق تصحُ الوكالة فيها باتفاق العلماء.

•التوكيل بالخصومة - كالمحاماة اليوم :-

فتجوز في حقوق الناس؛ لما روي أن عليًا وُكِّلَ عقيلًا في الخصومة عند أبي بكر وعمر، ووُكِّلَ جعفرًا عند عثمان؛ ولأن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيها؛ إذ قد لا يُحسِنُ المرءُ الدفاعَ عن حقوقه، أو يكره أن يتولَّى الخصومة بنفسه.

• الوكالة في الشهادة والأيمان والندور:

لا تصح؛ كأن يقول: وكَلْتُكَ أن تشهد عني بكذا؛ لأن حكمها متعلق بعلم الشاهد، وكذا لو قال: أن تحلف عني أو تنذر عني؛ لأنها تعلّقت بعين الناذر والحالف.

• وتجوز الوكالة بقبض الدّين وقضائه، وتجوز في الهبة، والصدقة، والإعارة، والإيداع، والمطالبة بالشفعة، والصلح والإبراء والعتق.

كما تجوز الوكالة بالنكاح، والطلاق، والخلع، والرجعة، ولا تصح الوكالة في الإيلاء والظهار.

أحكام الوكالة:

1- الوكالة العامة:

اختلف العلماء في جواز الوكالة العامة، كأن يقول الموكل: اشتر لي ما شئت أو ما رأيت. فقال الحنفية والمالكية بجوازها مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع والصفة والتمن؛ لأنه فوّض الرأي إليه كما في عقد المضاربة.

وقال الحنابلة والشافعية: لا يصح التفويض العام كأن يوكله في كل قليل وكثير؛ لوجود الغرر الكثير الذي لا ضرورة إلى احتماله، ولا بد وأن تكون الوكالة خاصة في ثوب معين أو بيت معين ونحو ذلك.

2- الوكيل يوكل غيره:

ليس للوكيل أن يوكل فيما وكّل فيه إذا كان يتولاه ولم يعجزه إلا أن يأذن له في التوكيل.

3- حكم عقد الوكالة:

الوكالة عقد جائز؛ لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما حق فسخها متى شاء.

4- صفة يد الوكيل:

يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي حتى ولو كانت الوكالة بجعل؛ لأن الوكيل نائب عن الموكل في التصرف فيما تحت يده، فكانت يده كيده، فكما أن المالك لا يضمن ما تلف في يده من ملكه، فكذلك وكيله.

5- دعوى الوكالة:

إذا ادعى أنه وكيل صاحب الحق، وأنه وَّكَّله في قبض الحق منه، وصدَّقه من عليه الحق في ذلك، فإنه لا يجب عليه دفع الحق إليه إلا إن أقام بينةً على دعواه.

6- الوكالة في قضاء الدَّين:

يلزم الوكيل أن يشهد على قضاء دَين الموكل؛ كيلا يرجع عليه الدائن بالقضاء، فإذا دفع الوكيل الدَّين دون إَشهاد، وأنكر صاحب الدَّين الوفاء، لم يقبل قوله الوكيل عليه، وبقي دَينه في ذمة الموكل.

7 - تعدد الوكلاء:

قال جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة: إذا تعدَّد الوكلاء فليس لأحدهم الانفراد بالتصرف بدون مشاورة الآخر، إلا إذا أذن لهم الموكل بإفراد التصرف، فيجوز لكل واحد منهم أن يستقل بالتصرف دون الرجوع إلى الآخر.

والحنفية يقولون بجواز أن يقوم كل واحد بما وَّكِّل به دون حاجة لاستشارة الآخر.

8 - اختلاف الموكل مع الوكيل:

قد يختلف الموكل مع الوكيل في بعض الأمور؛ كتلف ضياع ما في يد الوكيل أو في التعدي والتفريط، أو الاختلاف في التصرف، أو الاختلاف في الرد، ولقد عَلِمنا أن يد الوكيل يد أمانة؛ لهذا فإن الغالب أن يُقْبَلَ قولُ الوكيل بيمينه عند الاختلاف؛ لأنه منكر، والقول دائماً قول المنكر بيمينه، مع اختلاف وتفصيل يرجع إليه في كتب الفقه الموسعة.

9- واجبات الوكيل:

يتوجَّب على الوكيل عمومًا التقيُّد بالقيود، ومراعاة الشروط المبينة في الوكالة المقيدة، ومراعاة العُرف والعادة في الوكالة المطلقة، وعليه في الشراء أن يشتري بثمرن المثل عملاً بالعرف، وشراء السلعة السليمة من العيوب.

الربا: تعريفها و أنواعها وحكمها

تعريف الربا:

لغة: ربا الشيء يربو ربواً ورباءً: زاد ونما، وفي التنزيل العزيز {وَيُرِي الصَّدَقَاتِ} سورة البقرة (276) أي يزيدها وينميها.

والمرايبي: الذي يأتي الربا.

والربا في الاصطلاح الشرعي:

اختلف الفقهاء في تحديد معناه تبعاً لاختلافهم في مدلوله عندهم.

1- فعرّفه الشافعية بأنه: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهم¹، ويقصدون بالشرط الأول من هذا التعريف (ربا الفضل) عندهم، وبالشرط الثاني (ربا النسيئة) و(ربا اليد).

2- وعرفه بعض فقهاء الحنابلة بأنه: الزيادة في أشياء مخصوصة².

3- أما علماء المالكية فقد ذكروا أن الربا يوجد في شيئين: في البيع، وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك، وجعلوا الربا الجاهلي من الأنواع المتفق عليه³.

4- وعند الحنفية أنه: فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال⁴.

حكم الربا:

حرام بالإجماع، وكبيرة من كبائر الذنوب، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فالقرآن الكريم تحدث عن الربا في عدة مواضع مرتبة ترتيباً زمنياً، ففي العهد المكي نزل قول الله - سبحانه -: {وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} سورة الروم (39).

وفي العهد المدني نزل تحريم الربا صراحة في قول الله - سبحانه -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} سورة آل عمران (130)، وقال سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} سورة البقرة (275)، وآخر ما ختم به التشريع قول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ} * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (279/278) سورة البقرة.

وهذه الآية رد قاطع على من يقول: إن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافاً مضاعفة، لأن الله لم يبح إلا رد رؤوس الأموال دون الزيادة عليها.

وهو من كبائر الإثم فعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اجتنبوا السبع الموبقات)، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات).⁵

وقد لعن الله كل من اشترك في عقد الربا، فلعن الدائن الذي يأخذه، والمستدين الذي يعطيه، والكاتب الذي يكتبه، والشاهدين عليه.

جاء عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعن الله آكل الربا، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه)⁶، ورؤي عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية)⁷، وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم)⁸.

قال الماوردي: وأجمعت الأمة على أن الربا محرم "حتى قيل أنه لم يحل في شريعة قط لقوله - تعالى - {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} (161) سورة النساء.

يقول ابن حجر: عد الربا كبيرة هو ما أطبقوا عليه اتباعاً لما جاء في الأحاديث الصحيحة من تسميته كبيرة، بل هو أكبر الكبائر وأعظمها⁹.

أنواع الربا:

قسم الجمهور الربا إلى نوعين: ربا الفضل، وربا النساء، والفضل في اللغة الزيادة، والنساء التأخير. وذهب الشافعية إلى أن الربا أنواع ثلاثة: ربا الفضل، وربا النساء، وربا اليد، فربا الفضل والنساء عندهم كمثليهما عند الجمهور، وربا اليد عندهم يكون في البيع الذي لم يشترط فيه الأجل ولكن تأخر فيه فعلاً قبض أحد البديلين، وهو عند الحنفية كالبيع المنجز لا يجري فيه الربا إلا بزيادة أحد البديلين عن الآخر في العقد، فإن تساويا فلا ربا لعدم اشتراط الأجل.

1- ربا الفضل:

وهو: زيادة عين مال شرطت في عقد بيع على المعيار الشرعي "وهو الوزن أو الكيل" عند اتحاد الجنس.

ونص النبي - صلى الله عليه وسلم - على تحريم ربا الفضل في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) ¹⁰.

هذه الأعيان المنصوص عليها ثبت الربا فيها بالنص والإجماع.

واختلف أهل العلم فيما سواها فحكى عن طاووس وقتادة أنهما قصرا الربا عليها، وقالوا: لا يجري في غيرها، وبه قال داود ونفاة القياس، وقالوا: ما عداها على أصل الإباحة لقول الله - تعالى -: {وأحل الله البيع}.
واتفق القائلون بالقياس - وهم الجمهور - على أن ثبوت الربا فيها بعلّة، وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علته؛ لأن القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة هذا الحكم، وإثباته في كل موضع وجدت علته فيه، وقول الله - تعالى -: {وحرم الربا} يقتضي تحريم كل زيادة، إذ الربا في اللغة الزيادة، إلا ما أجمعنا على تخصيصه، وهذا يعارض ما ذكره، ثم اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد، إلا سعيد بن جبير فإنه قال: كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، كالحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب، والذرة بالدهن؛ لأنهما يتقارب نفعهما، فجريا مجرى نوعي جنس واحد، وهذا يخالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم) فلا يعول عليه، ثم يبطل بالذهب بالفضة فإنه يجوز التفاضل فيهما مع تقاربهما، واتفق المعلنون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما، فروي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات أشهرهن أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنس، وعلة الأعيان الأربعة مكيل جنس، نقلها عن أحمد الجماعة، وذكرها الخرقى وابن أبي موسى وأكثر الأصحاب، وهو قول النخعي والزهري، والثوري وإسحاق، وأصحاب الرأي، فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوماً كان أو غير مطعوم كالحبوب والأشنان والنورة، والقطن والصوف، والكتان والورس، والحناء والعصفر، والحديد والنحاس ونحو ذلك، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء) - وهو الربا - فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أرايت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ فقال: (لا بأس إذا كان يداً بيد). ¹¹

وقالت الشافعية: العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات، وغيرها لعدم المشاركة، والعلة في الأربعة الباقية: كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم. ووافق مالك الشافعي في الذهب والفضة.

أما في الأربعة الباقية فقال: العلة فيها كونها تدخر للقوت، وتصلح له. وأما مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فهو أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي الأربعة الكيل، فيتعدى إلى كل موزون، وإلى كل مكيل.

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "اتفق جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؛ بجنسه إلا مثلاً بمثل، إذ الزيادة على المثل أكل للمال بالباطل"¹²

2- ربا النسيئة:

هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية، ويعرف بالزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. أن يدفع أحدهم للآخر مالاً لمدة، ويأخذ كل شهر قدرًا معيناً، فإذا حل موعد الدين ولم يستطع المدين أن يدفع رأس المال أجل له مدة أخرى بالفائدة الذي يأخذها منه، وهذا هو الربا الغالب في المصارف وغيرها ببلاد المسلمين، وقد حرمه الله - تعالى - على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم الأخرى.

ولا شك أن ربا النسيئة لا خلاف في تحريمه بين الأمة جمعاء، إنما الخلاف في ربا الفضل بين الصحابة وابن عباس - رضي الله عنهم - أجمعين، وقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه رجع عن قوله وانضم إلى الصحابة في القول بتحريم ربا الفضل.

وربا النسيئة تحريمه ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلّم - قال: (ألا إنما الربا في النسيئة)¹³.

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: "كان معتمد ابن عباس وابن عمر حديث أسامة بن زيد (إنما الربا في النسيئة)، ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك، وقالوا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض، متفاضلاً حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً.

قال ابن حجر: "اتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، فقيل: منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

وقيل: المعنى في قوله: (لا ربا) الربا الأغلظ الشديد المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضاً نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالة بالمنطوق، ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدّم، والله أعلم".¹⁴

فاتّضح مما تقدّم تحريم: ربا الفضل، وربا النسيئة فلا إشكال في ذلك، والله الحمد.
وقد زاد بعض الشافعية نوعاً آخر من أنواع الربا وهو ربا القرض كما جاء في الحديث: (كل قرض جر منفعة فهو ربا)¹⁵.

المراجع والمصادر:

- 1 المجموع شرح المذهب للنووي (25/10).
- 2 ابن قدامة المغني (491/4).
- 3 ابن رشد الحفيد بداية المجتهد ونهاية المقتصد (216/5).
- 4 رد المحتار لابن عابدين (184/4).
- 5 البخاري ومسلم.
- 6 رواه أحمد والطبراني في المعجم الصغير وزيادته وصححه الألباني.
- 7 أخرجه أحمد وقال الألباني: سنده صحيح على شرط الشيخين.
- 8 رواه ابن ماجة وصححه الألباني.
- 9 الزواجر لابن حجر الهيتمي (309).
- 10 رواه مسلم.
- 11 رواه أحمد وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف، لكن أوله في صحيح مسلم.
- 12 فتاوى ابن تيمية (347/20).
- 13 رواه البخاري.
- 14 فتح الباري لابن حجر (382/4).
- 15 قال الألباني: رواه الحارث عن علي، وضعفه الألباني في الجامع الصغير، وفي ضعيف الجامع.

الشفعة: تعريفها، أقسامها، شروطها و حكمها

تعريف الشفعة:

لغة: بضم الشين وسكون الفاء، من الشفع وهو الزوج والضم، وسميت شفعة؛ لأن الشفيع يضم ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه.

اصطلاحًا:

هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك مَن انتقلت إليه بعوض، فهي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.

مشروعيتها: وهي مشروعة بالسنة والإجماع:

اتقاء الضرر الذي ينشأ من المجاورة من الدخيل الأجنبي الذي يأتي على الدوام، فقد يصدر منه سوء خلق أو معاملة، فيضطره للقسمة التي تكلف الشريك النفقة الزائدة، فيحل محلّ الوثام الشقاق والنزاع بين الجيران، وتنفوت مصالح ويكثر الضرر؛ لذا وجّه الشارع هذا الراغب شراءه لكونه هو الأولى والأحق، فإن لم يرغب باعه لمن يشاء، قال - صلى الله عليه وسلم - : - من كان له شريك في رُبْعَةٍ أو نَخْلٍ، فليس له أن يبيع حتى يؤذَنَ شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك [2].

أقسام الشفعة:

أركانها: عند الجمهور للشفعة ثلاثة أركان:

- 1- الشفيع: وهو الذي له حق الشفعة
 - 2 - المشفوع عليه: وهو الآخذ منه، وهو الذي انتقل إليه ملك نصيب الشريك القديم.
 - 3- مشفوع فيه: وهو الشيء الذي يريد الشفيع أن يملكه بالشفعة.
- وزاد المالكية ركنًا رابعًا: هو الصيغة.

أولاً: الشفيع:

الجمهور يقولون [3]: بأن الشفيع هو الشريك فقط؛ لأن الشارع خصّه في الشريك الذي لم يقاسم، وهو الذي يشترك مع غيره في الأصل وملحقاته كما جاء في الحديث ((في كل مالٍ يقسم.)) وقال الحنفية [4]: الشفيع هو الشريك أو الجار، واستدلوا بأحاديث: منها ((جارُ الدار أحقُّ بدار الجار والأرض)) [5]، و ((الجار أحق بالشفعة)) [6].

عند الجمهور [7]: يقسم العقار المشفوع فيه بين الشفعاء على قدر حصصهم أو أنصبتهم في الملك، فلو كانت الأرض بين ثلاثة، لواحد نصفها والآخر ثلثها والثالث سدسها، فباع الأول حصته، يأخذ الثاني سهمين والثالث سهمًا.

والحنفية يقولون [8]: إن لم يكن الشركاء في مرتبة واحدة، فإنه يقدم الشريك في المبيع، ثم الشريك في حق الارتفاق، ثم الجار، وإن كانوا في مرتبة واحدة قسم العقار بين الطالبين جميعًا.

ثانيًا: المشفوع عليه:

ويشترط أن يكون قد انتقل الملك إليه بعوض) يعني بشراء، (ولو انتقل الملك إلى الشريك الجديد بغير عوض لم يكن للشريك القديم أن يأخذ الشخص بالشفعة) كأن ينتقل إليه بميراث، أو وصية، أو صدقة، أو هبة. والدليل على هذا أن الأحاديث وردت في البيع، وهذه ليست في معناه.

ثالثًا: المشفوع فيه:

1- اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا شفعة إلا في العقار من دُور، وأرضين، وبساتين، وما يتبعها من بناء أو شجر، وأنه لا شفعة في منقول؛ كالحيوان، وعروض التجارة، والأمتعة، ودليله حديث جابر))): الشفعة في كل شرك في أرض أو رُبع أو حائط)) [9].

وأجازها الظاهرية في المنقول وغيره كالحيوان.

2- ويشترط في العقار ونحوه حتى تثبت فيه الشفعة أن يكون قابلاً للقسمة، والعقار القابل للقسمة هو الذي إذا قسم كل قسم منه يكون صالحاً لتحقيق المنفعة المقصودة منه.

شروط الشفعة:

1- خروج العقار عن ملك صاحبه خروجًا لا خيار فيه.

2- أن يكون العقد عقد معاوضة، وهو البيع وما في معناه.

3- أن يكون العقد صحيحًا، فلا تثبت الشفعة في المشتري شراءً فاسدًا.

4- ألا يصدر من الشفيع ما يدل على رضاه ببيع العقار المشفوع فيه وإعراضه عن الشفعة مدة طويلة من غير عذر، فيسقط حقه في طلب الشفعة.

5- أن يبادر الشفيع إلى طلب الشفعة بحسب الإمكان؛ (لحديث)) الشفعة كحل العقال [10].

حكم الشفعة:

الشفعة جائزة للشفيع، وتثبت الشفعة في كل شيء لم يقسم من أرض، أو دار، أو حائط، ويحرم التحيل لإسقاطها؛ لأنها شُرعت لإزالة الضرر عن الشريك.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمَ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّقَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. متفق عليه.

وقت الشفعة:

1- الشفعة حق للشريك متى علم بالبيع، فإن أخرها بطلت شفעתه إلا أن يكون غائباً، أو معذوراً فيكون على شفעתه متى قدر عليها، وإن أمكنه الإشهاد على المطالبة بها ولم يشهد بطلت شفעתه.

2 - إذا مات الشفيع ثبتت الشفعة لورثته، ويأخذ الشفيع المبيع بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت.

ثبوت الشفعة:

لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن له وقال لا غرض لي فيه لم يكن له المطالبة به بعد البيع.

حكم شفعة الجار:

الجار أحق بشفعة جاره، فإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكل منهما لقوله عليه الصلاة والسلام: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

المراجع والمصادر:

[1] البخاري وأحمد.

[2] رواه مسلم.

[3] ينظر: بداية المجتهد، 2/253، المهذب، 1/377، كشف القناع، 5/285، المغني، 4/149.

[4] ينظر: بدائع الصنائع، 5/4، تبين الحقائق، 5/239.

[5] أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما.

[6] أخرجه الترمذي.

[7] ينظر: الشرح الكبير، 3/486 بداية المجتهد، 2/257 مغني المحتاج، 2/305 المذهب، 1/381 المغني 5/335.

[8] بدائع الصنائع، 5/8 الباب. 2/106.

[9] مسلم.

[10] ابن ماجه

التأمين - تعريفه، أقسامه وحكم عقود التأمين في حياة الإنسان

تعريف التأمين:

التأمين حديثُ النَّشأة؛ فقد ظهرَ بِمَعْنَاهُ الحَقِيقِيّ في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين السوكرة [1] بأنواعه المختلفة لم يُعرَف إلا في أول القرن العشرين؛ فقد صدر أول قانون له في ألمانيا سنة 1901م، وهو نظام للوقاية من الخسارة بالتعويض، يتفق فيه عدد من الأفراد على دفع مبلغ محدد لضمان، أنهم سيُعوضون عند خسارة أي شيء معين بسبب الحريق، أو الحوادث، أو الوفاة، أو غيرها من الأسباب [2]، وعقد التأمين هو عقد لتخفيف أو تقليل ما يتعرّض له المؤمن له من خطر [3].

عرف القانون المدني الأردني عقد التأمين في المادة (920)، والتي جاء فيها: "التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، أو تحقق الخطر المبين في العقد؛ وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤدّيها المؤمن له للمؤمن" [5].

عرّف الأستاذ مصطفى الزرقاء نظام التأمين بقوله: "نظام تعاقدّي يقوم على أساس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاوّل عقودَه بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية" [6].

أما شركة التأمين، أو هيئة التأمين بوجه عام، فقد سماها النص "المؤمن"، ويدفع المؤمن له للمؤمن عادة أقساطًا شهرية أو سنوية مُتساوية القيمة، وقد يدفع اشتراكًا دوريًا يتفاوت مقداره؛ كما في جمعيات التأمين التبادلية، وقد يدفع مبلغًا مقطوعًا جملة واحدة؛ كما إذا دفع هذا المبلغ في مقابل أن يتقاضى من المؤمن إيرادًا مرتبًا مدى حياته، والمؤمن يدفع عادةً للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر مبلغًا من المال، وقد يدفع له أي عوض مالي آخر، كما إذا قام بتجديد البناء المحترق، كما في التأمين من الحريق، أو إصلاح السيارة، كما في التأمين ضد حوادث السير [7].

أوصاف عقد التأمين [8]:

1- عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية، وليس من عقود التبرعات؛ لأنه يقوم على أساس المبادلة، ويستهدف فيه كلا الطرفين الحصول على منفعة مقابل ما يؤدّيه إلى الطرف الآخر، فالمؤمن ملتزم بتسليم التعويض المالي للمتضرر، والمؤمن له ملتزم بدفع البدل، يقابل ذلك عقد التبرع الذي لا يقوم على المبادلة، فلا يأخذ فيه المتعاقد مُقابلًا لما يعطي [9].

- 2- عقد التأمين عقد جديد لم يرد ضمن زمرة العقود المسماة في الفقه الإسلامي؛ ولهذا يقوم على الاجتهاد في استنباط الأحكام النازمة له، وقد نُظمت أحكامه في القانون المدني والقوانين الخاصة به، فأصبح من العقود المسماة في القانون، وله أحكام خاصة به، يُلتزم بها عند التعاقد [10].
- 3- عقد التأمين من عقود الغرر أو العقود الاحتمالية [11]، وليس من العقود المحددة [12]؛ لأنَّ الحادث المؤمن ضده من الأمور التي يتوقع المؤمن والمؤمن له حدوثه في المستقبل، فالحادث غير موجود عند التعاقد، لكنَّه يحتمل الوجود في المستقبل، ووقوعه لا يدَّ لأحد المتعاقدين فيه، وهذا هو معنى الغرر.
- 4- عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين وقت إبرامه؛ لأنَّ الالتزامات في هذا العقد متقابلة، المؤمن دائن من ناحية ومدين من ناحية أخرى، والمؤمن له دائن من ناحية ومدين من ناحية أخرى، وهذه الالتزامات تثبت بالعقد، والعقد مصدرها، ولا يملك أحد المتعاقدين فسخ العقد أو إنهاء بإرادته المنفردة، إلا إذا وجد سبب شرعي أو قانوني يُجيز ذلك.
- 5 - عقد التأمين عقد زمني أو ممتد؛ لأنَّ الزمن عنصر جوهري فيه؛ لأنَّ التأمين يكون ضد حادث يحتمل الوقوع في المستقبل، والتأمين يمتد إلى فترة زمنية متفق عليها، غالبًا ما تكون سنة، فإذا وقع الحادث المؤمن ضده، خلال هذه السنة والتي يشملها التأمين، تقوم الشركة المؤمنة بالتعويض عن الضرر، وإن وقع الحادث بعد انتهاء المدَّة فلا تلتزم الشركة بشيء؛ لأنَّ التأمين ينتهي بانتهاء مدته.
- 6 - عقد التأمين عقد رضائي، ينعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول دون حاجة إلى إجراء شكلي؛ لأنَّ الفقه والقانون لم يشترطا أن يتم التأمين بشكل خاص [13]، كالتسجيل في دائرة معينة، أو تصديقه لدى جهة رسمية، كما هو الحال في عقد الزواج، أو عقد بيع السيارات والعقارات.
- 7- عقد التأمين من عقود الإذعان، لأنَّ المؤمن طرف قوي يملئ إرادته على طرف ضعيف وهو المؤمن له، ويقوم المؤمن بإعداد عقد التأمين مسبقًا، ولا يملك المؤمن له إلا التوقيع عليه ودفع البدل، خاصة في التأمين الإلزامي.

أقسام التأمين:

ينقسم التأمين إلى ثلاثة أقسام:

أ - **التأمين الاجتماعي:** [14]، ويشمل التأمين ضد البطالة، والتأمين الصحي، والتأمين ضد العجز، وتأمين المعاشات، وهذا التأمين عادة تقوم به الدولة أو المؤسسات الاقتصادية والصحية الحكومية؛ لتأمين الموظفين والعمال والمستخدمين، وخلاصته أن يستقطع مبلغًا معينًا من مرتب الموظف أو العامل أثناء فترة عمله، وتضيف إليه الدولة مبلغًا آخر، وعند نهاية الخدمة أو الإصابة التي تُعيق الموظف أو العامل عن الاستمرار في العمل يُعطى معاشًا شهريًا ثابتًا، أو يُصرف للمصاب تعويض مناسب، فضلاً عن نفقات العلاج، وهذا النوع من التأمين جائز شرعًا باتفاق العلماء، لخلوه من شبهة الغرر والربا، وعملاً بقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ المائدة. [2] :

ب - **التأمين التعاوني:** وهو أن يتفق عدة أشخاص، على أن يدفع كل منهم اشتراكًا معينًا؛ لتعويض الأضرار التي قد تُصيب أحدهم إذا تحقق خطر مُعَيَّن، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية، وهذا التأمين لا شك في جوازه شرعًا؛ لأنه يدخل في عقود التبرعات، ومن قبيل التعاون على البر؛ لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطر، وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، أيًا كان نوع الضرر، سواء في التأمين على الحياة، أو الحوادث الجسمية، أو على الأشياء، وغالبًا ما يكون ذلك بين أصحاب الحرفة الواحدة؛ كالعُمَّال والمهندسين والأطباء، أو أبناء العشيرة الواحدة؛ للتعاون على ترميم آثار المصيبة التي تقع على رأس أحدهم.

ج - **التأمين التجاري:** وهو ما تقوم به شركات التأمين التجارية، ويشمل ذلك:

- 1- التأمين على الحياة.
 - 2- التأمين ضد الحوادث.
 - 3- التأمين على النقل.
 - 4- التأمين ضد الحريق.
 - 5- التأمين ضد السطو على المساكن وسرقتها.
- وهذا التأمين يقوم على فكرة الربح والخسارة؛ ولهذا اختلف العلماء في حكمه، وبه انحصر الخلاف بين الفقهاء في هذا العصر [15].

آراء الفقهاء في التأمين التجاري:

اختلف العلماء في موضوع التأمين بالأقساط مع شركات التأمين التجارية إلى فريقين:

الأول :المانعون.

وهم يَرُون عقد التأمين حرامًا، ولا يحلُّ فيه أخذ التعويض من جانب المستأمن، ولا أخذ القسط من جانب المؤمن، وأصحاب هذا الرأي هم الأكثر عددًا، ومنهم الشيخ محمد بنيت المطيعي الحنفي مفتي الديار المصرية سابقًا، والأستاذ محمد أبو زهرة، والأستاذ وهبة الزحيلي، والشيخ عبدالرحمن قراعة، والدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور جلال مصطفى الصياد[16]، واستدلوا على رأيهم بما يلي:

1- عقد التأمين من عقود الغرر[17] المنهي عنها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الغرر"[18].

ووجه الغرر في التأمين أنَّ الحادث المؤمن ضده، يحتمل الوجود في المستقبل، ويحتمل العدم، ولا يتوقَّف وجوده أو عدمه على إرادة المتعاقدين، وهذا غرر كثير لا يُغتفر في عقود المعاوضات المالية؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً أو قسطين، ثم تقع الكارثة، فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدِّد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وهذا غرر فاحش مفسد لعقود المعاوضات المالية.

2- عقد التأمين التجاري، ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية، أو تسبُّب فيها، ومن الغنم بلا مُقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الحادث المؤمن ضده فيغنم المؤمن أقساط التأمين دون مقابل، والجهالة في ذلك فاحشة، وهو بهذا يدخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90] :

3- عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو الورثة أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسيئة، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسيئة فقط، وكلاهما محرَّم بالنص والإجماع.

4- عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرّم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ النساء. [29] :

5 - في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً؛ فإنّ المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبّب في حدوثه، وإنما كان منه مجرّد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على التقدير وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه المستأمن، والمؤمن لم يبدل عملاً للمستأمن، فكان حراماً [19].

6 - التأمين على الحياة يعدّ اجترأً على قضاء الله تعالى وقدره، فمن عقيدة المسلم، أن الأعمار بيد الله تعالى الذي يقول ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ لقمان [34] :، فمن يتعهّد لغيره أن يعيش كذا من العمر وإلا كان ضامناً لورثته مبلغاً من المال، وكذا الذي يعتمد هذا القول ويتعاقد على أساسه طمعاً في التعويض، كلاهما خارج على مقتضى هذه العقيدة الإسلامية [20].

والفريق الثاني: المجيزون:

ويرى هذا الفريق جواز التأمين بجميع أنواعه إذا خلا من الربا، ومن هذا الفريق الأستاذ مصطفى الزرقا والأستاذ محمد يوسف موسى، والأستاذ عبدالرحمن عيسى، والشيخ على الخفيف، والشيخ عبدالوهاب خلاف وغيرهم [21]، واستدلوا على رأيهم بما يلي:

أ - التأمين عقد جديد، لم يردّ نصّ على تحريمه، والأصل في العقود الجديدة الإباحة لا التّحريم؛ ولهذا يكون عقد التأمين مباحاً؛ لاندراجه تحت هذا الأصل العام.

ب - التأمين نظام تعاوني يقوم على مبدأ توزيع المخاطر وتشتيتها بين أكبر عدد ممكن من الأفراد الذين يتعرّضون لنفس الخطر، والله سبحانه وتعالى يقول ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ المائدة [2] :، والتأمين يكون مباحاً؛ لاندراجه تحت هذا الأصل التشريعي العام.

ج - دليل القياس، ويشمل قياس التأمين على ما يلي:

1 - عقد الموالاة، وصورته أن يقول شخص مجهول النسب لآخر معلوم النسب: أنت وليي، تعقل [22] عني إذا جنيت، وترثني إذا أنا مت، وهذا يعني أن عقد الموالاة يقيم رابطة حقوقية بين عاقديه شرعاً، قوامها التزام شخص بأن يحمّل الموجب المالي عن جناية الخطأ الصادرة من الآخر في مقابل أن هذا

الملتزم يَرِث الآخر إذا مات دون وارث، وهذه الرابطة سُمِّيت ولاء الموالاة، وهو صورة حيّة من صور عقد التأمين من المسؤولية [23].

2- ضمان خطر الطريق، وصورته: أن يقول شخص لآخر: اسلك هذا الطريق، فإنه آمن، وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن، فسلّكه فأخذ ماله، حيث يضمن القائل، وهو ما نصّ عليه الحنفية [24] في الكفالة، والتأمين على الأموال من الأخطار كذلك، فيأخذ حكمه وهو الجواز.

3- الوعد الملتزم عند بعض المالكية، ومثال ذلك: لو قال شخص لآخر: بع كرمك الآن، وإن لحقتك من هذا البيع خسارة فأنا أرضيك، فباعه بالخسارة، كان على الواعد أن يُرضيه بما يساوي ثمن ذلك المبيع، والعدة كانت سبباً للالتزام، وكذلك التأمين؛ لأن المؤمن وعد والتزم بتحمّل الخسارة والتعويض عنها، عند وقوع الحادث المؤمن ضده.

4 - نظام العواقل [25] في الإسلام، وصورته: أنه إذا جنى شخص جناية قتل غير عمد، وكان موجبها الأصلي الدية، فإنّ دية النفس توزّع على أفراد عاقلته الذين يحصل بينه وبينهم التناصّر عادةً، وهم الرجال البالغون من أهله وعشيرته، وكل من يتناصر هو بهم، ويُعتبر هو واحداً منهم، فتقسط الدية عليهم في ثلاث سنين بحيث يتحمل أفراد العاقلة الدية، والتأمين كذلك؛ لأن التعويض المالي المقرر عند وقوع الحادث المؤمن ضده يوزع على مجموع المستأمنين، وهذا هو التعاون على ترميم أثر المصيبة بعد وقوعها، بدل أن تقع على رأس فرد واحد، وقد لا يستطيع أن يتحمّلها بمفرده [26].

5 - عقد الاستئجار على الحراسة، وصورته أن الأجير الحارس، مُستأجر على عمل يؤدّيه هو القيام بالحراسة، وأثر هذا العمل هو تحقيق الأمان للمستأجر على الشيء المحروس، وعقد التأمين كذلك لأنه يعطي الأمان إلى المؤمن له من نتائج الأخطار التي يخشاها، وقام بتأمين نفسه ضدها [27]

الترجيح:

يظهر وبعد مناقشة أدلة العلماء في التأمين التجاري أنّ علة المنع هي الاستغلال، ومن صوره الجهالة والربا والغرر والقمار، وهذا يعني أن التأمين في حد ذاته جائز شرعاً بشرط أنوعه وصوره شريطة خلوه من الاستغلال؛ وهذا لا يتحقق إلا في التأمين التعاوني؛ لأنه يندرج تحت مبدأ التعاون في وجوه البر التي أقرها الإسلام، ويخلو من شبهة الغرر والجهالة والقمار والربا، وبهذا نقول: الأصل في التأمين الجواز، ما لم يوجد مانع شرعي لذلك.

حكم التأمين:

(1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة

(2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار (الميسر) (المحرم بنص القرآن " : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "

فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .

(3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .

إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .

(4)التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن " : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . "

فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .

فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .

المراجع والمصادر:

- [1] لفظ السوكرة الشائع بين الناس في البلاد العربية، بمعنى عقد التأمين، آت من اللفظ الفرنسي سيكورتية بمعنى الأمان والاطمئنان؛ الأستاذ الزرقا: نظام التأمين ص. 21 :
- [2] د .عبدالرزاق السنهوي :نظرية العقد ص:887 ، ود .وهبة الزحيلي :الفقه الإسلامي وأدلته (4 / 441).
- [3] د .محمد البهي :الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة ص.(17) :
- [4] جمعية الحقوقيين :قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ص.233 :
- [5] نقابة المحامين :المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني .915 / 2)
- [6] الأستاذ مصطفى الزرقا :نظام التأمين ص.19 :
- [7] د .عبدالرزاق السنهوي :الوسيط في شرح القانون المدني المصري .1085 / 7
- [8] يوسف كمال :كتاب الزكاة وترشيد التأمين المعاصر ص 26 :وما بعدها، ود .عبدالخالق حسن :الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية الإماراتي (
- [9] د .عبدالرزاق السنهوي :الوسيط (163 / 1) وما بعدها، ود .وحيد الدين سوار :النظرية العامة للالتزامات ص.41 :
- [10] الأستاذ مصطفى الزرقا :نظام التأمين ص 33 :وما بعدها.
- [11] العقد الاحتمالي أو عقد الغرر :هو الذي لا يستطيع فيه أحد المتعاقدين أن يُحدّد عند العقد مقدار غنّيه وغرّمه بمقتضى عقده، وإنما يتحدّد ذلك في المستقبل، تبعاً لأمر مجهول، أو غير محقق الحصول، ولا يد لأحد المتعاقدين في حصوله، كعقد الجعالة.
- [12] العقد المحدد، هو الذي يستطيع فيه كلا الطرفين أن يحدد عند إبرامه قيمة ما يأخذ بمقتضاه، وقيمة ما يُعطي، دون أن يتوقف تحديد هذه القيمة على أمر احتمالي غير محقق الوقوع؛ كعقد البيع، ويقابل ذلك عقود الغرر.
- [13] د .عبدالخالق حسن :الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية الإماراتي 44 / 5 ود .عبدالله النجار : عقد التأمين ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي ص.23 :

- [14] د .زكريا القضاة :السلم والمضاربة ص451 ،، ود .محمد البهي :الإسلام في حل مشاكل المجتمعات المعاصرة (ص178 ،، وعبدالسميع المصري :التأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص10 ،، ود .وهبة الزحيلي :الفقه الإسلامي وأدلته (442 / 4)، والأستاذ مصطفى الزرقا :نظام التأمين ص.55 :
- [15] الأستاذ مصطفى الزرقا :نظام التأمين ص (25 :وما بعدها، ود .وهبة الزحيلي :الفقه الإسلامي وأدلته (442 / 4)وما بعدها، ود .عبدالرزاق السنهوري :الوسيط (1088 / 7وما بعدها، ود .زكريا القضاة :السلم والمضاربة ص451 :وما بعدها.
- [16] د .عيسى عبده :التأمين بين الحلّ والحُرمة ص(166 ،، والأستاذ مصطفى الزرقا :نظام التأمين ص : 25وما بعدها، ود .وهبة الزحيلي :الفقه الإسلامي وأدلته .442 / 4
- [17] عرّف الحنفية الغرر بأنه :الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم، بمنزلة الشكّ، وعرفه السرخسي بأنه ما يكون مستور العاقبة :انظر :الكاساني :البدائع (263 / 5)، ود .ياسين درادكة :نظرية الغرر / 1 71.
- [18] النووي :صحيح مسلم بشرح النووي (3 / 5)، وابن ماجه :سنن ابن ماجه .(10 / 2)
- [19] يوسف كمال :كتاب الزكاة وترشيد التأمين المعاصر ص.68 :
- [20] الأستاذ مصطفى الزرقا :نظام التأمين ص.47 :
- [21] د .عبدالله مبروك :عقد التأمين ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي ص 200 :وما بعدها، ويوسف كمال :كتاب الزكاة وترشيد التأمين المعاصر ص 45 :وما بعدها، ود .عيسى عبده :التأمين بين الحلّ والحُرمة ص 148 :وما بعدها، والأستاذ مصطفى الزرقا :نظام التأمين ص 33 :وما بعدها.
- [22] العقل :دفع الدية أو التعويض المالي في جنابة الخطأ.
- [23] الأستاذ مصطفى الزرقا :نظام التأمين ص.29 :
- [24] الأستاذ مصطفى الزرقا :نظام التأمين ص.58 :
- [25] ابن عابدين :رد المختار على الدر المختار .345 / 3
- [26] الأستاذ مصطفى الزرقا :نظام التأمين ص60 ،، ود .عبدالله النجار :عقد التأمين ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي ص 279 :وما بعدها.
- [27] الأستاذ مصطفى الزرقا :نظام التأمين ص.51 :

الحالة: تعريفها وحكمها

تعريف الحالة:

تعريفها:

لغة: من التحويل والانتقال.

وفي الاصطلاح: هي نقل الدين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر.

مشروعيتها:

الحالة بالدين جائزة بالسنة والإجماع، استثناء من منع التصرف في الدين بالدين؛ قال - صلى الله عليه وسلم - ((مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) [1]، وفي رواية ((وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ)) [2]. وأجمع العلماء على جواز الحالة، وأنها عقد جائز في الديون دون الأعيان؛ لأن التحويل يكون في الدين ولا يكون في العين.

أركانها:

عند الجمهور - غير الحنفية - للحالة ستة أركان:

- 1- مُحِيل: وهو المدين.
- 2- محال: وهو رب الدين، أو الدائن.
- 3- محال عليه: وهو الذي التزم الدين للمحال.
- 4- محال به: وهو نفس الدين الذي للمحال على المحيل.
- 5- دين للمُحِيل على المحال عليه.
- 6- الصيغة، وهي الإيجاب والقبول.

شروطها:

- 1- أن يكون كلٌّ من المحيل، والمحال عليه، والمحال: عاقلًا، بالغًا.
- 2- أن يكون المحال عليه أملاً - أغنى - من المحيل؛ لأنه بدون ذلك لا يكون للحالة فائدة.
- 3- ويشترط لصحة الحالة: رضا الكل؛ المحيل والمحال عليه والمحال، وهناك مَنْ لم يشترط رضا المحال عليه.
- 4- أن يكون هناك دين للمحال على المحيل، فإن لم يكن دين فيكون وكالة.
- 5- واشترط المالكية أن يكون الدين المحال به قد حلَّ.
- 6- ويشترط اتفاق الدينين؛ أي: تماثلهما جنسًا ووقتًا وقدرًا.

حكم الحالة:

- 1- إذا صحَّت الحالة بأن اجتمعت شروطها نُقِلَ الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل بمجرد الحالة، فلا يملك المحال الرجوع على المحيل، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذَّر لمطلِّ أو فلس أو موت.
- وقال الحسن البصري: لا يبرأ المحيل على المحال عليه بدين في ذمة.

2- وَمَنْ أَحِيلَ بِثَمَنٍ مَبِيعٍ بِأَنْ أَحَالَهُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِهِ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا، فَلَا.

أنواع الحوالة:

للحوالة نوعان:

أ - الحوالة المقيدة:

أي أن يُحِيلَهُ وَيَقْتِدَهُ بِالَّذِينَ الَّذِينَ لَهُ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ هِيَ الْحَوَالَةُ الْجَائِزَةُ عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ.

ب - الحوالة المطلقة:

أي أن يُحِيلَ شَخْصٌ غَيْرَهُ بِالَّذِينَ عَلَى فُلَانٍ دُونَ تَقْيِيدِ ذَلِكَ بِالَّذِينَ الَّذِينَ عَلَيْهِ، وَيَقْبَلُ الْحَالَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَهَذِهِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَقَطْ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ.

حوالة الحق:

هي نقل الحق من دائن إلى دائن؛ أي: حلول دائن محل دائن آخر بالنسبة للمدين، وهي تقابل حوالة الدَّين التي تتضمن تبديل مدين بمدين، وحوالة الحق جائزة باتفاق المذاهب الأربعة.

انتهاء الحوالة: تنتهي الحوالة بأحد الأمور التالية:

• فسخ الحوالة.

• أن يهلك حق المحال بموت أو إفلاس أو غيره عند الحنفية دون الجمهور.

• أداء المحال عليه المال إلى المحال.

• أن يموت المحال ويرث المحال عليه مال الحوالة.

• أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبل الهبة.

• أن يتصدق المحال على المحال عليه ويقبل الصدقة.

• أن يبرئ المحال المحال عليه.

شروط الرجوع في الحوالة:

• أن تكون الحوالة بأمر المحيل.

• أداء مال الحوالة أو ما هو في معنى الأداء كالهبة والصدقة إذا قبل المحال عليه، وكذا إذا ورث المحال عليه المحال.

• ألا يكون للمحيل على المحال عليه دين مماثل للدين الذي أحيل به المحال، فإذا كان هناك دين وقعت المقاصة بينهما.

المراجع والمصادر:

[1] رواه أحمد والبيهقي.

[2] في أحكام الحوالة، ينظر: فتح القدير، 5/444 بداية المجتهد، 2/294 المهذب، 1/337 مغني المحتاج، 2/193

المغني، 4/522 كشف القناع، 3/473 الشرح الكبير، 3/225 الموسوعة الفقهية الكويتية 95